



บทที่ 3

สถานการณ์ของกฎหมายอิสลาม

ข้อความทั่วไป

กฎหมายอิสลามเป็นระบบกฎหมายคำสอนซึ่งเป็นระบบกฎหมายหนึ่งของโลก โดยใช้บังคับกับประชาชนทั้งหมดที่นับถือศาสนาอิสลาม แม้อันตรายโครงสร้างทางสังคม การเมืองได้เปลี่ยนแปลงไป ทำให้แนวความคิดทางด้านนิติศาสตร์เปลี่ยนแปลงไปด้วย สิ่งก่อให้เกิดการนิบัติปฏิบัติ สิ่งที่เราเรียกว่ากฎหมายนี้ จะต้องเป็นคำสั่งของรัฐาริปัตย์เป็นสำคัญ อย่างไรก็ตามภายใต้กฎหมายต่าง ๆ ของรัฐนั้นยังมีขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของแต่ละชุมชน ซึ่งสมาชิกของชุมชนได้ยึดถือปฏิบัติต่อกันมาอย่างเคร่งครัด สิ่งเหล่านี้แม้จะไม่ใช่มุขหมายของรัฐ (State Law) ก็ตาม แต่สมาชิกในสังคมก็ยอมรับขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีเหล่านี้จึงมีสถานการณ์เป็นกฎหมายอย่างหนึ่งเช่นกัน คือ เป็นกฎหมายแห่งการดำเนินชีวิต (Living Law) ซึ่งมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากฎหมายของรัฐ เพราะกฎหมายแห่งการดำเนินชีวิตนั้นได้กำหนดความผิดถูกของเขาเอง ซึ่งบางกรณีอาจจะแตกต่างจากตัวบทกฎหมาย¹

กฎหมายอิสลามหรือที่เรียกว่าชาโรอะห์ (Shariah) คือ คำสอนอันถูกต้องเกี่ยวกับหน้าที่ต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยคำสอน สังคม การเมือง ชีวิตภายในครัวเรือนและชีวิตส่วนตัว

¹Ehrlich ซึ่งเป็นนักนิติศาสตร์เป็นผู้เสนอทฤษฎี Living Law โดยแยกอธิบายกฎหมายออกเป็น 2 ส่วน คือ State Law กับ Living Law State Law คือ กฎหมายที่รัฐรับรู้ เช่น กฎหมายที่ออกโดยรัฐสภาหรือกฎหมายที่วิธานนิติศาสตร์พัฒนาขึ้นมาและรัฐรับรู้ คือที่ปรากฏในประมวลกฎหมาย เป็นกฎหมายทางการของรัฐ แต่ในรัฐหรือในสังคมก็มีกฎหมายอีกชุดหนึ่งเรียกว่า กฎหมายในชีวิตที่มีความสัมพันธ์ระหว่างคนในสังคมเรียกว่า Living Law

ดู ประวัติ เกษมทรัพย์, นิติปรัชญา ภาค 2 บทบาททางประวัติศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), หน้า 17.

โดย ผู้ใช้ทั่วไป

ดาวน์โหลดเมื่อ 21/08/2569 14:34:50

ของผู้นับถือศาสนาอิสลาม เป็นความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ของมนุษย์ ชะรีอะฮ์ หมายถึง ธรรมวินัย (กฎหมาย) ของศาสนาอิสลาม ผู้กำหนดกฎหมายนี้ คือ อัลลอฮ์ ภายในกฎหมายนี้ บรรจุไว้ด้วยเจตนารมณ์ของอัลลอฮ์ ชะรีอะฮ์เป็นธรรมนูญอันถูกต้องสำหรับชีวิตของบุคคล ซึ่ง อัลลอฮ์ทรงกำหนดไว้เป็นมาตรฐานในการตัดสินการกระทำของมนุษย์ว่าผิดหรือถูก สำหรับมุสลิมแล้ว ชะรีอะฮ์ถือว่าเป็นธรรมนูญสมบูรณ์แบบของกฎหมายอิสลามในด้านสิทธิและหน้าที่ของมุสลิมแต่ละคน¹

จะเห็นว่า แม้กฎหมายอิสลามจะไม่เป็นกฎหมายของรัฐที่ถือว่าเป็น Positive Law ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็แต่จากกฎเกณฑ์ที่ประกาศใช้โดยผู้ปกครองหรือโดยรัฐ² แต่เพียงอย่างเดียว แต่กฎหมายอิสลามมีส่วนที่เป็นกฎหมายธรรมชาติ เพราะกฎหมายอิสลามมีที่มาจากเจตนารมณ์ของพระเจ้าเป็นเจ้าและวัตถุประสงค์ของกฎหมายอิสลามก็ช่วยให้มนุษย์เคารพเจตนารมณ์นี้ ฉะนั้นเมื่อรัฐได้นำเอากฎหมายแห่งเกี่ยวกับครอบครัวและมรดกมาบังคับใช้ในประเทรัฐจึงต้องนำเอากฎหมายอิสลามมาบังคับใช้กับมุสลิมเพื่อให้สอดคล้องกับหลักกฎหมายอิสลามที่ประชาชนส่วนหนึ่งยึดถือปฏิบัติติดต่อกันมาเป็นเวลานาน

สถานการณ์ของกฎหมายอิสลามในยุคของคำสดา

ในยุคของคำสดาระบบกฎหมายอิสลาม (Islamic Legal System) ยังไม่มี เพราะอำนาจการนิติบัญญัติขึ้นอยู่กับคำสดาเพียงผู้เดียว ที่มาของกฎหมายอิสลามจึงมีเพียงคัมภีร์กุรอาน (Qur'an) และจริยวัตร (Sunnah) ของคำสดา ส่วนที่มาของกฎหมายอิสลาม

¹ สมาคมนิติศึกษาศึกษาไทยมุสลิม, อะไรในอิสลาม, เอกสารเผยแพร่คำสนา อันดับที่ 1 2521, หน้า 135.

² โภคิน พลกุล, กฎหมายมหาชน เอกสารประกอบคำบรรยาย, ภาควิชา กฎหมายมหาชน, (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525,) หน้า 19.

ส่วนอื่น ๆ เช่น อัล-อิญมาอ์ (Ijma) และ อัล-กียาส (Giyas) นั้นเป็นเพียงได้พัฒนาขึ้นภายหลังเท่านั้น¹

ภายหลังการสิ้นชีวิตของคาลิฟาอาหมาดการไช้และประมุขบทบัญญัติได้เปลี่ยนมาขึ้นอยู่กับกาหลิบ (Caliph) เนื่องจากกฎหมายอิสลามยังมิได้รวบรวมเอาไว้ในระหว่างที่คาลิฟามีชีวิตอยู่ กาหลิบและสหายจึงได้รวบรวมกฎหมายอิสลาม (Islamic Law) และระเบียบข้อกำหนดเพื่อใช้ในรัฐหรือชุมชนมุสลิม (Ummah) แต่เมื่อมีปัญหาทางด้านนิติศาสตร์เกิดขึ้น ก่อนอื่นกาหลิบในขณะนั้น คือ กาหลิบอับ บักร (Abu Bakar) จะต้องดูที่บทบัญญัติคัมภีร์ก่อนในเรื่องนั้น ๆ เป็นอันดับแรก แต่เมื่อไม่อาจค้นหาความหมายชัดเจนได้ในคัมภีร์ก่อนเขาจะต้องอ้างอิงถึงจริยวัตร (Sunnah) และวัจนะ (Hadith) ของท่านคาลิฟา แต่ถ้าจริยวัตรและวัจนะไม่อาจแก้ไขปัญหาได้เขาจะต้องขอคำปรึกษาจากสหาย (เช่นอะฮับะฮ์) วิธีการเช่นนี้กาหลิบองค์ต่อ ๆ มาก็ได้ยึดถือปฏิบัติมา² สิ่งเป็นที่แน่ชัดว่าที่มาของกฎหมายอิสลามในขณะนั้นก็คือ คัมภีร์ก่อน, จริยวัตรและวัจนะของคาลิฟา ส่วนอิญมาอ์และกียาสนั้นเป็นที่มาของกฎหมายภายหลัง แต่ก็ต้องอยู่บนพื้นฐานของคัมภีร์ก่อน, จริยวัตรและวัจนะ

ความแตกต่างของแนวความคิดด้านนิติศาสตร์เริ่มปรากฏให้เห็นในระยะนี้ เพราะว่ากาหลิบองค์ต่อ ๆ มามีความเห็นแตกต่างกันในต้นฉบับของคัมภีร์ก่อน, จริยวัตรและวัจนะ³

แม้กฎหมายอิสลามจะครอบคลุมเรื่องต่าง ๆ เกือบทุกเรื่องในชีวิตประจำวันแต่สาระสำคัญส่วนใหญ่อยู่ที่เรื่องครอบครัวมรดก เพราะเป็นนิติสัมพันธ์ที่ปกติแล้วเป็นเรื่องภายในของอิสลามคำสนธิที่จะทำกันเอง เพื่อให้มีผลระหว่างกันโดยไม่เกี่ยวข้องกับคนภายนอกคำสนธิข้อนี้จะถือว่าเป็นปรัชญาอย่างหนึ่งของกฎหมายอิสลามก็ได้ นอกเหนือไปจากปรัชญาอื่น ๆ ที่สำคัญ เช่น ปรัชญาที่ว่ากฎหมายอิสลามเป็นองค์การของพระผู้เป็นเจ้าจึงไม่มีทางที่จะสบล้าง

¹ Azizan B. Abdul Razak, Conflict Resolution : Personal Laws System, Civil Law System and Muslim School of Law, 1st Asean Shariah Administrators Conference Workshop, August 7-11, 1983, Manila, Philippines, p. 1.

² Ibid.,

³ Ibid., p. 2.

แล้วแต่เดิมชั้นใหม่ กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือจะสร้างอำนาจนิติบัญญัติชั้นใหม่ไม่ได้ เว้นแต่เป็นการสร้างกฎระเบียบมีขัดกับคำสอนอิสลามเพราะเหตุฉะนั้น กฎหมายจึงไม่เปลี่ยนแปลง (dynamic) ไปตามสังคม ประโยชน์ข้อนี้จะได้เห็นได้ชัดขึ้นในเรื่องของครอบครัวมรดก

สถานการณ์ของกฎหมายอิสลามในยุคผู้สืบทอด (Successor)

ภายหลังการสิ้นสุดของสหราชอาณาจักร กฎหมายอิสลามก็ได้เข้าสู่ศักราชใหม่ ซึ่งอำนาจนิติบัญญัติขึ้นอยู่กับผู้สืบทอดการนิติบัญญัติในยุคนี้ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว กฎหมายอิสลามได้เผชิญหน้ากับสถานการณ์ใหม่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีใหม่ของชาวมุสลิม¹ สำนักกฎหมายอิสลาม (School of Law หรือ Madahib) ซึ่งปรากฏขึ้นในยุคนี้ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่มีความเห็นแตกต่างกันขึ้นมาเบื้องต้นของกฎหมายอิสลาม

สำนักกฎหมายอิสลามที่มีชื่อเสียงอยู่ 4 สำนัก คือ

1. สำนักฮานาฟี (Hanafi) ซึ่งมีอิมาม ฮานิฟา (Hanifah) เป็นเจ้าสำนักและมีจำนวนผู้ใช้ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศอินเดียตอนเหนือ ซีเรีย อิหร่านและตุรกี
2. สำนักกฎหมายมาลิกี (Maliki) ซึ่งมี อิมาม อับดุลลอฮ์ เป็นเจ้าสำนักและมีจำนวนผู้ใช้ส่วนใหญ่อยู่ในทวีปอาฟริกาตอนเหนือ มอริสโคโคและสเปน
3. สำนักกฎหมายชาฟีอี (Shafie) ซึ่งมีอิมามมุฮัมหมัด บิน ฮิดรอส บินชาฟีอี เป็นเจ้าสำนัก และมีจำนวนผู้ใช้ส่วนใหญ่อยู่ในอินเดียตอนใต้ ศรีลังกา มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย
4. สำนักกฎหมายฮัมบาลี (Hanbali) ซึ่งมีอิมามอาหมัด บิน ฮัมบาลเป็นเจ้าสำนักและมีจำนวนผู้ใช้ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มประเทศอาหรับทั่วไป²

¹ Azizan B. Abdul Razak, Conflict Resolution : Personal Laws System, Civil Law System and Muslim School of Law, 1st Asean Shariah Administrators Conference Workshop, August 7-11, 1983, Manila, Philippines, p. 1.

² ธรรมศักดิ์ ธีระพินิจ. ความเป็นมาของกฎหมายอิสลามและตะกิดะยูติธรรม (นศรศีธรรมราช : โรงพิมพ์ศรีอักษร 2518), หน้า 18-20.

นอกจาก 4 สำนักกฎหมายอิสลามที่มีชื่อเสียงนี้แล้วในกลางศตวรรษที่ 1 (A.H) ถึงต้นศตวรรษที่ 4 (A.H) มีสำนักกฎหมายอิสลามไม่น้อยกว่า 19 สำนัก และมีอิทธิพลพอ ๆ กับ 4 สำนักดังกล่าว แต่ต่อมาสำนักกฎหมายอิสลามเหล่านั้นได้ค่อย ๆ หายไปที่ละน้อย จนกระทั่งเหลือเพียง 4 สำนัก ซึ่งมีผู้นับถือเกือบทั่วทั้งหมดยกของโลกอิสลาม¹

ปัจจัยที่ช่วยให้สำนักกฎหมายมีความมั่นคง โดยเฉพาะ 4 สำนักกฎหมาย คือ

1. บทบาทของผู้ที่นับถือของแต่ละสำนักซึ่งได้เผยแพร่คำสอนของสำนักในพื้นที่ของพวกเขาเอง
2. การรวบรวมคำสอนของเจ้าสำนักกฎหมายซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมหาศาลต่อสาธารณชนในอันที่จะเข้าใจในคำสอนของสำนัก
3. บทบาทของผู้ปกครองในการส่งเสริมคำสอนของสำนักกฎหมายที่ตนยึดถือ เช่น การแต่งตั้ง Qadi จะจำกัดเฉพาะผู้ที่สังกัดอยู่ในสำนักกฎหมายเท่านั้น เพราะสาธารณชนจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของ Qadi โดยอัตโนมัติ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในทางด้านนิติศาสตร์ เช่น กาลิฟ Abbasid ได้ยอมรับสำนักกฎหมายฮานาฟีเป็นสำนักกฎหมายทางการ²

กระนั้นก็ตามความรู้สึกเกี่ยวกับสำนักกฎหมายก็ยังไม่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจน จนกระทั่งถึงกลางศตวรรษที่ 4 (A.H) ซึ่งในขณะนั้นได้มีทฤษฎีทางนิติศาสตร์ที่จะพัฒนาระเบียบหรือวิธีการของหลักการ เพื่อที่จะหยั่งรู้ถึงความหมายของกฎหมายพระผู้เป็นเจ้า วิธีการที่จะพยายามหยั่งรู้ถึงความหมายของกฎหมายพระผู้เป็นเจ้านั้น ก็คือ Ijtihad ซึ่งเป็นการหาหนทางที่จะแก้ไขปัญหาทางนิติศาสตร์ในกรณีที่ไม่อาจหาคำตอบได้จากคัมภีร์กูรออันและซุนนะ (Sunna) ซึ่งจะทำให้ได้โดยการเทียบเคียงจากหลักทั่วไปเข้าสู่เรื่องเฉพาะ (Analogical deduction)³ ถ้าหากว่าความเห็นของนักนิติศาสตร์พ้องต้องกัน ความเห็นนั้นก็เป็น Ijma

¹ Azizan B. Abdul Razak, Conflict Resolution : Personal Laws System Civil Law and Muslim School of Law, p. 6.

² Ibid., pp. 6-7.

³ J. Duncan M. Derrett Ed, An Introduction to Legal System, London: Sweet & Maxwell, 1968, p. 63.

ต่อมาแนวความคิดที่พยายามแสวงหาเหตุผลเพื่อที่จะหยั่งรู้ความหมายของกฎหมายของพระผู้เป็นเจ้าได้ถึงกาลอวสาน สิ่งได้เกิดแนวความคิดของการเอาเยี่ยงอย่าง (Imitation) หรือที่เรียกว่า Taglid) ซึ่งในยุคนี้ นักนิติศาสตร์ไม่มีสิทธิที่จะพยายามแสวงหาเหตุผล ซึ่งจะทำให้ได้ก็เพียงเป็นผู้เอาเยี่ยงอย่าง (Imitators) โดยการจำกัดขอบเขตของตัวเองให้อยู่กับแนวความคิดที่ได้กำหนดขึ้นจากนักนิติศาสตร์คนก่อน ๆ เท่านั้น¹ ผลที่ติดตามมาก็คือ ได้มีการพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามของแต่ละสำนักเหล่านี้ขึ้นเป็นจำนวนมาก และต่อมาผู้นำคำสอนได้มีการแสดงความเห็นเป็นเชิงอธิบายหนังสือซึ่งแต่งโดยผู้เขียนคนก่อน ๆ ที่เป็นต้นฉบับ ในกรณีที่มีความเห็นแตกต่างกันระหว่างแต่ละสำนัก โดยปกติแล้วส่วนใหญ่จะไม่มี การยอมรับความเห็นของสำนักอื่น แต่จะเห็นพ้องกับความเห็นของสำนักที่ตนยึดถือ²

นับว่าแนวความคิดเกี่ยวกับการยึดถือแนวความคิดของนักนิติศาสตร์คนก่อน ๆ เพื่อการตัดสินได้ดำเนินต่อไปจนถึงต้นศตวรรษที่ 10 (A.H) ซึ่งแนวความคิดนี้ที่ยึดมั่นอยู่กับสำนักกฎหมายได้เป็นที่ยอมรับว่าเป็นของแท้จริงในกฎหมายอิสลาม

โลกมุสลิมทั้งหมดได้ใช้สำนักกฎหมายของตนเป็นสำนักของทางการ Qadi และผู้นำทางศาสนา (Ulema) จะได้รับแต่งตั้งก็เฉพาะแต่ผู้ที่สังกัดอยู่ในสำนักกฎหมายของทางการเท่านั้น จากท่าทีอันคับแคบของรัฐบาลมุสลิมเป็นการนำขบวนการกฎหมายอิสลามเข้าสู่จุดจบหรืออีกนัยหนึ่งชุมชนมุสลิมกำลังเผชิญหน้ากับความแตกต่างมากมายในการพิจารณาแก้ไขทางด้านนิติศาสตร์³

¹ J.Duncan M. Derrett Ed. An Introduction to Legal System, London, Sweet & Maxwell, 1968, p. 66.

² Azizan B. Abdul Razak, Conflict Resolution ; Personal Laws System Civil Law System and Muslim School of Law, p. 9.

³ Ibid., p. 10.

การร่างประมวลกฎหมายอิสลาม

จากแนวความคิดทางด้านนิติศาสตร์ที่ยึดถืออยู่เฉพาะแต่ความเห็นของสำนักกฎหมายใดกฎหมายหนึ่งแล้วปฏิเสธความเห็นของสำนักกฎหมายอื่นนั้น นับว่าเป็นการทำให้คุณค่าของกฎหมายอิสลามสูญหายไป สิ่งก่อให้เกิดแนวความคิดที่จะประมวลกฎหมายอิสลามขึ้น โดยรวบรวมความเห็นจากหลาย ๆ สำนัก

ก. การร่างประมวลกฎหมายแห่งอิสลามของตุรกี การประมวลกฎหมายอิสลามนั้นนับว่าได้ทำให้คุณค่าของกฎหมายอิสลามที่สูญหายไปกลับคืนมา รัฐบาลตุรกีที่อยู่ภายใต้จักรวรรดิออตโตมาน (Ottoman Empire) ได้ร่างประมวลกฎหมายอิสลาม ซึ่งเป็นการร่างขึ้นตามแนวความคิด การประมวลกฎหมายของตะวันตก (Western Legal Code) ซึ่งเรียกว่า Majallah al-Ahkam Al-Adliya ในปี 1286 (A.H.) ประมวลกฎหมายฉบับนี้ได้รวบรวมกฎหมายอิสลามในเนื้อหาตามกฎหมายแพ่ง โดยมีพื้นฐานจากคำสอนหลาย ๆ สำนัก ทั้งที่มีชื่อเสียงและไม่ค่อยมีชื่อเสียง¹

ข. การร่างประมวลกฎหมายแห่งอิสลามของอียิปต์ รัฐบาลอียิปต์ได้รับเอาแนวความคิดการร่างประมวลกฎหมายอิสลามมาใช้ ซึ่งก่อนปี 1920 ความเห็นของสำนักกฎหมายฮานาฟี เป็นสำนักของทางการซึ่งได้ใช้ในศาลคำสอนของอียิปต์ การจำกัดอยู่กับสำนักใดสำนักหนึ่งนั้นได้สร้างความยุ่งยากแก่สาธารณชนและผู้รอบรู้ทั่ว ๆ ไป ดังนั้น รัฐบาลอียิปต์จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมายอิสลามพิเศษขึ้นมา (Special Law Commission) ซึ่งประกอบด้วยผู้นำทางคำสอนและนักกฎหมาย เพื่อตรวจสอบกฎหมายที่ใช้อยู่ในขณะนั้น และถ้าเป็นไปได้ ความเห็นของสำนักกฎหมายอื่นก็อาจนำมาใช้ในศาลคำสอนได้ ผลที่ติดตามมาก็คือ ได้ประกาศใช้กฎหมายฉบับที่ 25/1920 กฎหมายฉบับนี้ได้เปิดโอกาสให้สำนักกฎหมายอื่น ๆ เช่น ชาฟีอี มาลิกี ฮัมบาลี ซึ่งความเห็นของสำนักเหล่านี้ก็อาจนำมาอ้างอิงได้ โดยเฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวกับคำเลี้ยงดู ีดาอ (Idda) การล่าปลุกและการหย่าอันเนื่องมาจากสภาพร่างกายที่ไม่อาจ

¹ Azizan B. Abdul Razak, Conflict Resolution ; Personal Laws System Civil Law System and Muslim School of Law, p. 10.

ร่วมประเวณีได้ ในปี 1929 รัฐบาลฮิบตีได้ออกกฎหมายฉบับที่ 25/1929 ซึ่งกำหนดให้การใช้กฎหมายอิสลามนั้นไม่จำกัดอยู่เฉพาะแต่ 4 สำนักเท่านั้น แต่ให้ใช้สำนักอื่น ๆ ได้ไม่ว่าสำนักนั้นเป็นที่ราบกันหรือไม่เป็นที่ราบกันโดยทั่วไปก็ตาม โดยเฉพาะในเนื้อหาเกี่ยวกับการหย่า การเรียกร้องเนื่องจากการหย่าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร (Separation Claim for Decent) ค่าเลี้ยงดู อิดาอ (Idda) การล่าปลูญ¹

เป็นที่น่าสังเกตว่า กฎหมายฉบับที่ 56/1923 เกี่ยวกับการจำกัดอายุของผู้ที่จะทำการสมรส ซึ่งได้กำหนดให้ผู้ที่จะทำการสมรสได้ คือ ชายต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และหญิงต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี ซึ่งเป็นไปตามความเห็นของ Ibni Shabrumah ซึ่งข้อกำหนดเช่นนี้จะไม่พบใน 4 สำนักกฎหมายดังกล่าว และต่อมาได้มีกฎหมายฉบับที่ 77/1943 ว่าด้วยการรับมรดก กฎหมายฉบับที่ 48/1946 ว่าด้วยการบริจาคเพื่อชุมชน (wakaf) และฉบับที่ 71/1946 ว่าด้วยการทำทักญีรรม ซึ่งบทบัญญัติตามกฎหมายอิสลามเหล่านี้ไม่ได้มีรากฐานมาจากคำสอนเฉพาะสำนักอานาฟีเท่านั้น แต่ก็มีรากฐานจากคำสอนของสำนักอื่นด้วยเช่นกัน²

สถานการณ์ของกฎหมายอิสลามในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในสมัยโบราณภูมิภาคแถบนี้มีรูปแบบของสังคม การเมืองเป็นลักษณะแว่นแคว้น โดยมีเจ้าผู้ครองนครแต่ละแว่นแคว้นทำการปกครองกันเอง การปกครองส่วนใหญ่มุ่งเป็นการรักษาความสงบและชืขาดัดสันคต โครงสร้างของสังคมยังไม่มี ความซับซ้อน ดังนั้น ขบวนการทางนิติบัญญัติจึงไม่มีความจำเป็น การตัดสินคดีความก็ใช้แต่เพียงขนบธรรมเนียมประเพณีก็เป็นการเพียงพอ³ ในกรณีแว่นแคว้นที่เป็นมุสลิมก็เช่นเดียวกันการตัดสินคดีความต่าง ๆ ก็ต้องเป็น

¹ Azizan B. Abdul Razak, Conflict Resolution ; Personal Laws System Civil Law System and Muslim School of Law, p. 11.

² Ibid., p. 11

³ ปรีดี เกษมทรัพย์, นิติปรัชญา ภาค 2 บทนำทางประวัติศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มิตรนาการพิมพ์ 2526), หน้า 22-23.

ไปตามขนบธรรมเนียมประเพณีและบทบัญญัติทางศาสนาอิสลาม ซึ่งกล่าวได้ว่าในยุคนั้นกฎหมายอิสลามมีสถานะภาพเป็นกฎหมายประจำแคว้นมุสลิม

ในระหว่างศตวรรษที่ 16-20 ชาวยุโรปได้เข้ามาทำการค้าขายในภูมิภาคนี้ แต่เนื่องจากความเจริญทางด้านอุตสาหกรรมของประเทศในยุโรป ในที่สุดก็เข้าครอบครองดินแดนส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้ ผลจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก ทำให้ดินแดนเหล่านี้เป็นปึกแผ่น ชาวพื้นเมืองต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันและอยู่ปกครองเดียวกัน¹ จึงก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างของสังคม² ซึ่งรวมทั้งขนบการนิติบัญญัติด้วย เดิมสถานภาพกฎหมายอิสลามนั้นเป็นกฎหมายประจำแคว้น จึงได้รับผลกระทบกระเทือนจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก เพราะเจ้าอาณานิคมได้นำเอารูปแบบปรัชญาทางกฎหมายมาใช้ในอาณานิคมของตน ซึ่งในยุคนั้นทั้งยุโรป อังกฤษและอเมริกามีแนวความคิดทางนิติปรัชญาตามสำนักกฎหมายที่ฝ่ายบ้านเมือง (Legal Positive)³ โดยถือว่ากฎหมายเป็นคำสั่งของรัฐบาลปัติย์ และกฎหมายเป็นกฎเกณฑ์ที่แตกต่างจากศีลธรรม⁴ ผลก็คือเจ้าอาณานิคมได้พยายามที่จะนำเอาหลักกฎหมายของตัวเองมาใช้แทนกฎหมายอิสลามในบางกรณี และได้จำกัดขอบเขตของการใช้กฎหมายอิสลาม โดยให้ใช้กฎหมายอิสลามเฉพาะในบางเรื่องและในบางพื้นที่เท่านั้น นอกจากนั้นแล้วเจ้าอาณานิคมได้พยายามจะประมวลกฎหมายอิสลามขึ้นเพื่อสะดวกต่อการใช้ โดยเฉพาะในเรื่องครอบครัวและมรดกตามแนวความคิดทางตะวันตก แม้ต่อมาประเทศต่าง ๆ ในเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะได้รับเอกราช แต่แนว

¹ ธรรมนูญ อานามวัฒน์, ประวัติศาสตร์และการวิเคราะหฺเอเชียปัจจุบัน (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์อักษรพิทยา, 2526), หน้า 198.

² ทมล ทองธรรมชาติ (กับคณะ), เอเชียความรู้ทั่วไป, สถาบันเอเชีย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า 85.

³ ปรีดี เกษมทรัพย์, นิติปรัชญา ภาค 2 บทนำทางประวัติศาสตร์, อ่างแล้ว, หน้า 21.

⁴ เรื่องเดียวกัน, หน้า 312-313.



ความคิดเกี่ยวกับการใช้กฎหมายอิสลามยังคงอยู่และได้รับการพัฒนาสืบมาภายใต้หลักการความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชนในชาติ ซึ่งขอเลือกบางประเทศที่มีการใช้กฎหมายอิสลามเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายของประเทศและควรนำมาเป็นแบบอย่างในการค้นหาวิธีการที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย ดังนี้

ก. สถานการณ์ของกฎหมายอิสลามในศรีลังกา

1. ลักษณะทั่วไปทางสังคมศรีลังกา ประเทศศรีลังกา มีประชากรประมาณ 14 ล้านคน มีชื่อเสียอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา (Democratic Socialist Republic of Sri Lanka) เดิมชื่อ ซีลอน (Ceylon) โปรตุเกสเป็นชาติแรกที่เข้าปกครองศรีลังกา หลังจากนั้นก็เป็นฮอลันดาและชาติสุดท้าย คือ อังกฤษ ศรีลังกาได้รับเอกราช เมื่อ พ.ศ. 2491

ประชากรศรีลังกาแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มเชื้อชาติ คือ

1. กลุ่มสิงหล มีประมาณ 2 ใน 3 ของประชากรทั้งหมด นับถือศาสนาพุทธ
2. กลุ่มทมิฬ มีฐานะเป็นชนกลุ่มน้อยของศรีลังกา
3. กลุ่มมัวร์ (Moor) ได้แก่พวกที่สืบเชื้อสายมาจากพ่อค้าชาวอาหรับ นับถือศาสนาอิสลาม
4. กลุ่มเบอร์เกอร์ (Burgher) ได้แก่กรณีที่มีเชื้อสายมาจากชาวต่างชาติหรือชาวยุโรปตั้งแต่ศรีลังกาเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก

ระบบกฎหมายของศรีลังกาใช้ระบบกฎหมายโรมัน-ดัตช์ และกฎหมายอังกฤษ (Roman-Dutch Law and English Law) ส่วนกฎหมายอิสลามก็ใช้กับชาวมุสลิม กฎหมาย Tesawalami ก็ใช้กับชาวทมิฬ และกฎหมาย Kandyan¹ ก็ใช้กับชาวสิงหลโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับครอบครัว-มรดก

¹ อุทัย หิรัญโต, การปกครองท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์โอเดียน สโตร์, 2523), หน้า 133-134.

2. สถานการณ์ของกฎหมายอิสลามก่อนการเข้ามาของลัทธิล่าอาณานิคม ก่อนการเข้ามาของโปรตุเกส พื้นที่ชายฝั่งของศรีลังกาที่เรียกว่า Sailah หรือ Serendib ได้มีพ่อค้าชาวอาหรับมาตั้งรกรากทำการค้าขาย และได้นำเอากฎหมายอิสลามและประเพณีต่าง ๆ มาใช้ในชุมชนของตนเอง โดยมีศาลพิเศษสำหรับพิจารณาคดี (Tribunal) ซึ่งนับว่าเป็นการเข้ามาครั้งแรกของกฎหมายอิสลามในศรีลังกา ในสมัยนั้นผู้ประกอบการท้องถิ่นก็ได้ยอมรับถึงสภาพบังคับกฎหมายประเพณีมุสลิม แต่การใช้กฎหมายอิสลามก็ยังคงใช้จำกัดอยู่แต่เฉพาะในชุมชนมุสลิมเท่านั้น¹

3. สถานการณ์ของกฎหมายอิสลามในระหว่างที่เป็นอาณานิคม ก่อนการเข้ามาของลัทธิล่าอาณานิคม สถานภาพของกฎหมายอิสลามก็เป็นเพียงจารีตประเพณีที่บังคับใช้ภายในชุมชนมุสลิม จนกระทั่งการเข้ามาของลัทธิล่าอาณานิคมของชาติตะวันตก สถานภาพของกฎหมายอิสลามเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ การเข้ามาของลัทธิล่าอาณานิคมก็เพื่อเผยแพร่คริสต์ศาสนาและเพื่อแสวงหาทรัพยากรจากชาติอาณานิคม ดังนั้น การปฏิบัติต่อชาวพื้นเมืองจึงเป็นไปในลักษณะทำลายล้าง โดยเฉพาะต่อมุสลิมที่ไม่อาจจะตอบสนองต่อนโยบายการเผยแผ่ศาสนาของเจ้าอาณานิคม แต่อย่างไรก็ตามเจ้าอาณานิคมก็ไม่อาจจะทนต่อสภาพการต่อต้านจากมุสลิม ประกอบกับเพื่อจะได้มีโอกาสแสวงหาผลประโยชน์ทางด้านการเมือง ทางด้านทรัพยากร เจ้าอาณานิคมจึงได้ยอมรับเอาหลักกฎหมายอิสลามมาใช้ในชุมชนมุสลิมได้

ในศรีลังกาการเข้ามาของโปรตุเกสในปี ค.ศ. 1505 ได้เข้ามาทำลายล้างมุสลิมอย่างกว้าง รวมทั้งทำลายขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ของมุสลิม ทำให้มุสลิมต้องอพยพไปตั้งมั่นในป่าเขา การบริหารกฎหมายอิสลามจึงได้รับผลกระทบกระเทือนเป็นอย่างมาก²

¹ Ahmed Hilmy Mohideen, Physical Organization of Shariah Courts in Sri Lanka, 1st Asean Shariah Administrators Conference Workshop August 7-11, 1983 Manila, Philippines, p. 2.

² Ibid., p. 2.

ต่อมาดัตช์ได้เข้ามาปกครองศรีลังกาในปี ค.ศ. 1650 มุสลิมได้ยืนยันถึงสิทธิที่จะอยู่ภายใต้กฎหมายประเพณี (Customary Law) และขนบธรรมเนียม (Usages) ของตน ดัตช์ได้เรียนรู้ถึงความจำเป็นที่จะต้องให้มีการใช้กฎหมายอิสลามจากอาณานิคมของตนเองใน ตะวันออกไกลและชวา (Ja wa) จึงได้ยอมรับสิทธิที่อยู่ภายใต้หลักกฎหมายอิสลามของมุสลิม โดยประกาศอนุญาตให้มุสลิมอยู่ภายใต้หลักกฎหมายอิสลามและจารีตประเพณีได้

เมื่อดัตช์ ได้ยอมให้นำเอาหลักกฎหมายอิสลามมาบังคับใช้ในชุมชนมุสลิมแล้ว ในเวลา ต่อมาก็ได้ประมวลกฎหมายอิสลามขึ้นเพื่อใช้กับมุสลิมชาวพื้นเมือง แต่ในขณะนั้นยังไม่มีคำล คำสนา เพื่อทำการพิจารณาคดี ประมวลกฎหมายมุสลิมนี้ ได้พิมพ์ขึ้นในฐานะ เป็นส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติ แห่งปัตตาเวีย (Statute of Batavia) และมีเนื้อหาในเรื่องที่เกี่ยวกับการสืบมรดก การ รับมรดก การแต่งงาน การหย่า การประมวลกฎหมายอิสลามนี้เป็นแต่เพียงรวบรวมเอาหลัก นิติศาสตร์อิสลาม (Islamic Jurisprudence) จากหนังสือหลาย ๆ เล่มรวมเอาไว้ ด้วยกัน¹

4. สถานการณ์ของกฎหมายอิสลามในระหว่างที่เป็นอาณานิคมของอังกฤษ การเข้า มาของอังกฤษในปี ค.ศ. 1796 ชาวมุสลิมพื้นเมืองได้ยืนยันถึงความต้องการที่จะอยู่ภายใต้ หลักกฎหมายประเพณีและขนบธรรมเนียม และได้รับการยอมรับจากรัฐบาลอังกฤษโดยทันที อังกฤษได้รับทราบถึงผลบังคับของพระราชบัญญัติปัตตาเวีย โดยประกาศ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 1799 ว่า ความยุติธรรมจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและขนบธรรมเนียมประเพณี ซึ่งมียู่ก่อนการปกครองของดัตช์ ดังนั้น ประมวลกฎหมายอิสลามที่นำมาใช้กับมุสลิมพื้นเมือง ภายใต้การปกครองของดัตช์จึงเป็นที่ยอมรับสำหรับขบวนการยุติธรรมเพื่อมุสลิม²

ต่อมาอังกฤษได้กฏบัตรแห่งความยุติธรรม โดยประกาศว่า ในเรื่องเกี่ยวกับการ สืบมรดก การรับมรดกที่ดิน การเช่าและการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายตกลงที่

¹ Ahmed Hilmy Mohideen, Physical Organization of Shariah Courts in Sri Lanka, 1st Asean Shariah Administrators Conference Workshop August 7-11, 1983 Manila, Philippines, p. 3.

² Ibid., p. 3.

จะใช้กฎหมายอิสลามและขนบธรรมเนียมของมุสลิม ให้ใช้กฎหมายอิสลามบังคับใช้ได้ ซึ่งนับว่าเป็นการยอมรับให้เอากฎหมายอิสลามมาบังคับใช้อย่างเด่นชัด¹

เมื่อสิทธิของมุสลิมที่จะอยู่ภายใต้หลักกฎหมายอิสลามได้ยอมรับจากอังกฤษตามประกาศดังกล่าวแล้ว ดังนั้น กฎหมายที่จะนำมาใช้นั้นจะต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีความชัดเจน ด้วยเหตุนี้ Sir Alexander John Stone ได้เสนอประมวลกฎหมายอิสลามที่เรียกว่า Code of Muhammadan Law ต่อสภาผู้ว่าราชการ (Geverner-in Council) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม ค.ศ. 1806 นับว่าเป็นประมวลกฎหมายที่ได้ประมวลขึ้นอย่างเป็นระบบ (System of Law) ประมวลกฎหมายฉบับนี้ในขั้นแรกให้ใช้บังคับเฉพาะในโคลัมโบ (Columbo) และต่อมาได้ขยายการใช้ออกไปทั่วประเทศ ในปี ค.ศ. 1852²

ประมวลกฎหมาย Muhammadan ได้กลายมาเป็นพื้นฐานของกฎหมายอิสลามที่ใช้ในศรีลังกา อย่างไรก็ตามประมวลกฎหมายนี้ยังขาดรายละเอียด และเนื้อหาบางประการก็ยังไม่ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่า กฎหมายอิสลามส่วนใดที่จะนำมาใช้ในศาลแพ่ง ซึ่งขณะนั้นยังไม่มีศาลศาสนา ดังนั้น ศาลแพ่งจึงได้สร้างหลักกฎหมายขึ้นมาเอง เมื่อได้นำเอาหลักกฎหมายอิสลามมาใช้ เช่น ดังคำพิพากษาเรื่องหนึ่งซึ่งได้วางหลักเอาไว้ว่า คำว่า Moors และ Muhammadan นั้นมีความหมายเหมือนกัน คือ ประชาชนชาวมุสลิมมีเชื้อสายมาจากอาหรับและได้แต่งงานกับชาวพื้นเมือง ได้อาศัยอยู่ในประเทศศรีลังกาเป็นเวลานาน นอกจากนี้ศาลยังได้กำหนดว่า กฎหมายอิสลามนั้นใช้บังคับได้กับทุกคนที่นับถือศาสนาอิสลามไม่ว่าจะมีเชื้อสายมาจากมาเลย์ ขาวหรือผู้อพยพมาจากอินเดีย อาฟกานิสถาน ซึ่งนับว่าเป็นการขยายขอบเขตของการใช้กฎหมายอิสลาม ซึ่งแต่ก่อนจำกัดอยู่แต่เฉพาะพวก Moor เท่านั้น³

นอกจากนั้นศาลยังได้กำหนดว่ากฎหมายอิสลามไม้อาจจะนำมาใช้ได้ทั้งหมด แต่ใช้ได้เพียงเฉพาะบางส่วนเท่านั้น และมีบางกรณีก็ไม่ได้กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายนี้ เมื่อมีปัญหา

¹ Ahmed Hilmy Mohideen, Physical Organization of Shariah Courts in Sri Lanka, 1st Asean Shariah Administrators Conference Workshop August 7-11, 1983, Philippines, p. 3.

² Ibid.

³ Ibid. p. 4.

ศาลแพ่งไม่ได้ขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญกฎหมายอิสลามและ Ulema แต่ศาลก็ไปค้นหาที่มาของกฎหมายอิสลามคือ คัมภีร์กุรอาน ฮาดิสและสุนนะฮ์, อิจญ์มา กียาส ซึ่งแหล่งที่มาทั้งหมดนี้มีเนื้อหากว้างขวาง และยังมีความเห็นที่แตกต่างระหว่าง 4 สำนักกฎหมาย คือ สำนักมาลิกี ฮัมบาลี ฮานาฟีและชาฟีอี โดยปกติแล้วศาลแพ่งมักจะอ้างถึงหลักกฎหมายตามความเห็นของสำนักกฎหมายชาฟีอี เพราะโดยทั่ว ๆ ไปมุสลิมในศรีลังกาจะนับถือนิกายซุนหนี่ ดังนั้นความเห็นของสำนักกฎหมายอื่น ๆ จึงไม่ได้รับการกล่าวถึง¹

สำหรับศาลที่ทำการพิจารณาคดีตามกฎหมายอิสลามในยุคนั้นได้กระทำในรูปแบบของที่ประชุมมัลลิต ทำการพิจารณาคดีเหมือนกับศาลคำสนา (Shariah Court) โดยไม่มีวิธีพิจารณาอะไรมากนัก การตัดสินก็ถือเอาตามความเห็นส่วนใหญ่ของที่ประชุม ศาลแพ่งจึงได้ระมัดระวังที่จะไม่เข้าไปก้าวก่ายในเรื่องที่เกี่ยวกับคำสนาอิสลาม เว้นแต่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิทธิทางแพ่งที่มีผลต่อทรัพย์สิน สำหรับที่ประชุมนั้นจะประกอบไปด้วยผู้นำชุมชนและผู้สูงอายุเป็นผู้ตัดสินข้อพิพาทและการลงโทษในบางกรณี เช่น การกระทำความผิดในทางประเวณีและลักทรัพย์ นอกจากนั้นยังต้องพิจารณาในเรื่องอื่น ๆ อีก เช่น การล้มรล การหย่า การเป็นผู้ปกครองเหล่านี้เป็นต้น ต่อมาอำนาจผลการบังคับของที่ประชุมได้ถูกตัดทอนลงเป็นอันมาก เนื่องจากมีประชากรโยกย้ายถิ่นฐานจึงหลุดพ้นจากพันธะทางสังคม (Loosening of Community bond) และประการที่สำคัญก็คือ การขยายอำนาจของศาลแพ่งที่ครอบคลุมไปถึงการกระทำทุกรูปแบบของวิถีชีวิตสังคม²

กฎหมายอิสลามได้นำมาใช้ในศาลแพ่ง โดยศาลแพ่งได้กำหนดขอบเขตการใช้กฎหมายอิสลามเอาไว้ว่า กฎหมายอิสลามจะต้องนำไปบังคับใช้กับมุสลิม โดยทั่ว ๆ ไปแล้วพลเมืองชาวมุสลิมก็เหมือนกับพลเมืองอื่น ๆ ทั้งหมดซึ่งจะต้องอยู่ภายใต้หลักกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา

¹ Ahmed Hilmy Mohideen, Physical Organization of Shariah Courts in Sri Lanka, 1st Asean Shariah Administrators Conference Workshop August 7-11, 1983, Philippines, p. 5.

² Ibid. p. 6.



แต่ภายในโครงสร้างของกฎหมายทั่ว ๆ ไปศาลได้ยกเลิกแบบอย่างที่เคยเป็นบรรทัดฐานมาก่อน เพื่อจะนำกฎหมายอิสลามมาบังคับใช้แก่มุสลิมเป็นการเฉพาะ¹ ดังนั้น กฎหมายอิสลามในบางเรื่องจึงได้กลายมาเป็นกฎหมายของประเทศ เป็นต้นว่า กฎหมายอิสลามว่าด้วยการให้ (Shariah Law governing Gifts) กฎหมายอิสลามว่าด้วยมรดกและกองทุนบริจาค กฎหมายสถานภาพบุคคลมุสลิมว่าด้วยการสมรส การหย่า ผู้เยาว์และอื่น ๆ

กฎหมายสถานภาพบุคคลมุสลิม (Muslim Law of Person)

กฎหมายสถานภาพบุคคลมุสลิมว่าด้วยการสมรส การหย่า ผลของการสมรส ผู้เยาว์ และความปกครองได้กลายมาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกฎหมายของประเทศ ซึ่งได้นำมาบังคับใช้เฉพาะกับมุสลิม แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมายเหล่านี้ไม่ได้ใช้ในศาล ทั้งศาลแพ่งและศาลศาลาอิสลามต่อไปอีก จนกระทั่งปี ค.ศ. 1931 เมื่อรัฐบาลได้ออกกฤษฎีกาว่าด้วยการจดทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า (Muslim Marriage and Diverce Registration) และต่อมาได้ก่อตั้งสำนักงาน Quazis หรือ Kathi ขึ้นทำหน้าที่เหมือนศาลศาลาอิสลาม เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการสมรส การหย่า และอื่น ๆ สืบเหตุที่รัฐจำเป็นต้องออกกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว ก็เนื่องจากมีความต้องการใช้กฎหมายอิสลามมีความชัดเจนแน่นอน และอีกประการหนึ่งก็เป็นการกำหนดขอบเขตอำนาจพิจารณาคดีของศาลศาลาอิสลามให้มีความแน่นอนโดยการบัญญัติเป็นกฎหมาย²

กฎหมายอิสลามที่เกี่ยวกับสถานภาพบุคคลมุสลิมในศรีลังกา มีดังนี้

ก. ประมวลกฎหมาย Mohamadan

ประมวลกฎหมาย Mohamadan ว่าด้วยการสมรส การหย่าของมุสลิมได้ยอมรับว่าการสมรสนั้นเหมือนกับสัญญาของคู่กรณีซึ่งมีความสมบูรณ์ที่จะต้องบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย

¹ Ahmed Hilmy Mohideen, Physical Organization of Shariah Courts in Sri Lanka, 1st Asean Shariah Administrators Conference Workshop August 7-11, 1983, Philippines, p. 6.

² Ibid. p. 14.

อิสลาม เป็นต้นว่า ความยินยอมของผู้ปกครองฝ่ายหญิง การประกอบพิธีสมรสซึ่งต้องกระทำต่อหน้าพยาน การกำหนดค่าสินสอดเหล่านี้ เป็นต้น นอกจากนั้นกฎหมายก็ไม่สนับสนุนการสมรสที่ที่เป็นข้อห้ามตามกฎหมายอิสลาม เช่น การมีภรรยาเกิน 4 คนในเวลาเดียวกัน การสมรสในระหว่างอิตตะฮ์ เป็นต้น

การใช้กฎหมายอิสลามตามประมวลกฎหมายนี้มีปัญหายุ่งยากเนื่องจากไม่มีการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการสมรส การหย่าจึงเป็นการยากแก่ทนายที่จะพิสูจน์ต่อศาลแพ่งว่าบิดามารดาได้สมรสกันตามกฎหมายอิสลาม หรือได้หย่าแล้ว หรือว่าการสมรสยังคงมีอยู่¹

ข. กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนสมรสของมุสลิมฉบับที่ 8 (Mohammadan Marriage Registration Ordinance)

เนื่องจากปัญหาที่เกิดจากการใช้กฎหมายอิสลามตามประมวลกฎหมายปัญหาเกี่ยวกับสำนักงานจดทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่าของมุสลิม จึงเป็นปัญหาที่ได้หยิบยกขึ้นมาพิจารณาและในปี ค.ศ. 1886 รัฐจึงได้ประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนสมรสของมุสลิม ซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดให้คู่สมรสของมุสลิมจะต้องทำการจดทะเบียน ซึ่งทำให้มุสลิมบางส่วนแต่ไม่ใช่ผู้นำทางศาสนาไม่เห็นด้วยกับกฎหมายฉบับนี้ โดยเห็นว่ารัฐบาลอาณานิคมได้เข้ามาแทรกแซงศาสนาอิสลาม จึงเป็นผลให้การจดทะเบียนสมรสนั้นเป็นเพียงทางเลือกทางหนึ่งของมุสลิมเท่านั้น²

ค. กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนสมรสและทะเบียนหย่าของมุสลิมฉบับที่ 27 ปี 1929 (Muslim Marriages and Divorce Registration Ordinance)

คำสั่งกฏต้องการที่จะใช้กฎหมายอิสลามในรูปแบบกฎหมายสถานภาพบุคคลมุสลิม (Muslim Law of Person) เพื่อการนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับ

¹ Ahmed Hilmy Mohideen, Physical Organization of Shariah Courts in Sri Lanka, 1st Asean Shariah Administrators Conference Workshop August 7-11, 1983, Philippines, p. 15.

² Ibid. p. 16.

วิธีพิจารณาความโดยการขจัดประเพณีต่าง ๆ ที่ขัดแย้งกับหลักกฎหมายอิสลาม และเพื่อเป็นการรักษาการอยู่ร่วมกันทางสังคมศาสนาของชุมชน (The Socio - Religious Cohesion) of Community) ด้วยเหตุนี้การจดทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่าจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง และยิ่งไปกว่านั้น ในปี ค.ศ. 1926 ศาลสูงได้ตัดสินว่า เฉพาะศาลแขวงเท่านั้นที่จะมีอำนาจอนุญาตให้ผู้ทำการสมรสภายใต้หลักกฎหมายอิสลามทำการหย่าได้ ดังนั้น ผลของการหย่าไม่ว่าในลักษณะใดตามกฎหมายอิสลามย่อมไม่มีผลและไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผลที่ติดตามมาก็คือ ได้มีการเร่งเร้าจากกลุ่มหรือสมาคมของมุสลิมต่อรัฐบาลอาณานิคม เป็นเหตุให้รัฐบาลได้ออกกฤษฎีกาฉบับที่ 27 ปี 1929 ว่าด้วยจดทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า นับว่ากฤษฎีกาฉบับนี้มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาการใช้กฎหมายอิสลามในศรีลังกา¹

ตามกฤษฎีกาฉบับนี้ถือว่าการจดทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่าเป็นเพียงพยานหลักฐานเบื้องต้นที่จะสามารถนำไปอ้างได้ในทุก ๆ ศาล แต่อย่างไรก็ตาม เพียงแต่การจดทะเบียนสมรส และทะเบียนหย่าไม่เป็นที่แสดงว่าการสมรส การหย่านั้นถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย กฤษฎีกาฉบับนี้ได้ยกเลิก Mohamadan Code 1806 แม้จะได้ยกเลิกกฎหมายดังกล่าว แต่ก็ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อการสมรส การหย่าและสิทธิต่าง ๆ ตามประมวลกฎหมายฉบับนี้²

กฤษฎีกาฉบับนี้ได้บัญญัติขึ้นภายใต้โครงสร้างของกฎหมายอิสลาม และมีการบริหารกฎหมายอิสลามที่สมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นการประกาศการหย่า หรือผลของการหย่า การจ่ายค่าเลี้ยงดูเหล่านี้ เป็นต้น ซึ่งกรณีเหล่านี้ไม่จำเป็นจะต้องนำคดีขึ้นสู่ศาลแพ่ง³

กฤษฎีกาฉบับนี้ได้กำหนดให้ Quazi เป็นนายทะเบียนเพื่อทำหน้าที่จดทะเบียนการสมรสของมุสลิมและได้ก่อตั้งคณะกรรมการ Qauzi³ เพื่อพิจารณาคำอุทธรณ์คำตัดสินของ Qauzi

¹ Ahmed Hilmy Mohideen, Physical Organization of Shariah Courts in Sri Lanka, 1st Asean Shariah Administrators Conference Workshop August 7-11, 1983, Philippines, p. 16.

² Ibid.

³ Ibid. p. 17.

จ. กฎหมายว่าด้วยการแต่งงานและการหย่าของมุสลิม ฉบับที่ 13 ปี ค.ศ. 1951
(Muslim marriage and divorce Act No. 13)

กฎหมายฉบับนี้ได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบกพร่องของกฎหมาย ว่าด้วย การจดทะเบียน สัมรสและทะเบียนหย่าของมุสลิมฉบับที่ 27 ปี 1929 แต่ยังคงระบบศาล Qauzi เอาไว้ซึ่งนับ ได้ว่ามีการก่อตั้งศาลคำสอนอิสลาม (Shariah Court) สำหรับการบริหารกฎหมายอิสลาม ที่เกี่ยวกับการแต่งงานและการหย่า ตลอดจนความสัมพันธ์ในด้านอื่น ๆ ขึ้นในศรีลังกาอย่าง แท้จริง¹

ข. สถานภาพของกฎหมายอิสลามในอินเดีย

1. ลักษณะทางสังคมของอินเดีย ลักษณะทางสังคมของอินเดียปัจจุบัน คือ เป็นสังคมกว้างใหญ่ซับซ้อน โดยมีความแตกต่างกันมากในหมู่ประชาชนชาวอินเดีย ชาวอินเดีย มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมาก มีประชาชนที่นับถือคำสอนที่สำคัญถึง 6 คำสอน คือ

1. คำสอนฮินดู มีผู้นับถือประมาณ 82 %
2. คำสอนอิสลาม มีผู้นับถือประมาณ 11 %
3. คำสอนคริสต์ มีผู้นับถือประมาณ 3 %
4. คำสอนพุทธ มีผู้นับถือประมาณ 1 %
5. คำสอนซิกข์ มีผู้นับถือประมาณ 2 %
6. คำสอนเชน มีผู้นับถือประมาณ 0.5 %

เนื่องจากสังคมอินเดียเป็นสังคมกว้างมีประชากรมาก และประชากรมีลักษณะที่ แตกต่างกันไป ปัญหาความขัดแย้งกันระหว่างประชาชนจึงมีมากเป็นทวีคูณ รัฐบาลอินเดีย ตระหนักดีว่าปัญหาความแตกต่างของสังคมและวัฒนธรรมในประเทศเป็นอุปสรรคต่อการปกครอง และการพัฒนาประเทศ รัฐบาลจึงได้พยายามหาทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้อยู่ตลอดเวลา เช่น ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคำสอนฮินดูกับคำสอนมุสลิม รัฐบาลอินเดียจึงได้พยายามหาทางแก้ไข

¹ Ahmed Hilmy Mohideen, Physical Organization of Shariah Courts in Sri Lanka, 1st Asean Shariah Administrators Conference Workshop August 7-11, 1983, Philippines, p. 17.

ปัญหาเหล่านี้มาเป็นเวลานาน โดยการจัดการปกครองประเทศอย่างเป็นเอกเทศจากคำสนาไม่รับรองหรือยกย่องคำสนาหนึ่งคำสนาใดเหนือคำสนาอื่น ไม่รับรองคำสนาใดเป็นคำสนาประจำชาติ และได้รับรองความเสมอภาคของประชาชนที่นับถือคำสนาทุกคำสนา¹

2. สถานการณ์ของกฎหมายอิสลามก่อนการเข้ามาของลัทธิล่าอาณานิคม อินเดียนโบราณเจริญรุ่งเรืองมาจนเป็นที่สนใจของชาวต่างชาติ ชาวอาหรับหรืออีกนัยหนึ่งชาวมุสลิมได้เคลื่อนกำลังบุกรุกอินเดียในราวศตวรรษที่ 8 การสู้รบกับผู้บุกรุกชาวมุสลิมเริ่มเข้มข้นขึ้นในราวศตวรรษที่ 11 ถึงปลายศตวรรษที่ 12 อินเดียหลายส่วนตกอยู่ในอำนาจปกครองของมุสลิมในศตวรรษที่ 13 เมืองเดลีก็ถูกยึดครองโดยลุลต่านชาวมุสลิม นับแต่นั้นมาอินเดียก็ตกอยู่ภายใต้การปกครองของชาวมุสลิม สิ่งที่ติดตามมาจากการถูกปกครองโดยชาวมุสลิม คือ ได้มีการเผยแผ่คำสนาอิสลามขึ้นในหมู่ประชาชนชาวอินเดีย² สิ่งนับได้ว่าเป็นการนำเอาหลักกฎหมายอิสลามมาใช้ในอินเดียเป็นครั้งแรก เพราะกฎหมายอิสลามย่อมจะติดตามไปกับผู้ที่นับถือคำสนาอิสลาม

3. สถานการณ์ของกฎหมายอิสลามในระหว่างเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ในขณะที่อินเดียอยู่ภายใต้การปกครองของชาวมุสลิม ชาวตะวันตกได้เริ่มทยอยการเข้ามาเพื่อแสวงหาอาณานิคม และตลาดการค้าไหมในภาคตะวันออกและอินเดีย นอกจากการทำการค้าขายทำให้ชาวตะวันตกเริ่มมีการขัดแย้งกันและนำไปสู่การสู้รบ สำหรับอินเดีย อังกฤษโดยการนำของบริษัทการค้าอินเดียตะวันออกได้รับชัยชนะในที่สุด และได้เริ่มการปกครองอินเดียอย่างแท้จริงในปี ค.ศ. 1757³ อินเดียตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษเป็นเวลานานถึง 200 ปี ได้รับเอกราชในปี ค.ศ. 1947

¹ เอเซียปริทัศน์, มหาสมุทรอินเดียและเอเชียใต้, สถาบันเอเชีย, ปีที่ 3 ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2525, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า 55-57

² เจริญ ไชยชนะ, ประวัติคำสตรประเทศในเอเชีย (พระนคร: เกษมบรรณกิจ, 2518), หน้า 79 กษัตริย์บางพระองค์ถึงกับบังคับพวกฮินดูให้นับถือคำสนาอิสลาม นโยบายนี้ทำให้พวกฮินดูก่อกบฏขึ้น

³ กระมล ทองธรรมชาติ (กับคณะ), เอเชียความรู้ทั่วไป, สถาบันเอเชีย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2525, หน้า 58.

กฎหมายอิสลามในอินเดียได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากในระหว่างที่ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษในปี ค.ศ. 1762 บริษัทอินเดียตะวันออกซึ่งมีอำนาจอธิปไตยในการปกครองอินเดียและมีอำนาจนอกเหนือจากที่ทำการค้าขาย เพื่อเป็นการคุ้มครองสถาบันต่าง ๆ ตามกฎหมายอิสลามที่เกี่ยวกับกฎหมายครอบครัว-มรดกและเรื่องอื่น ๆ ที่มีบทลงโทษทางศาสนา ซึ่งเป็นการให้หลักประกันแก่มุสลิม ฉะนั้นนอกเหนือจากกฎหมายเหล่านี้แล้วจะต้องใช้กฎหมายที่อังกฤษประมวลขึ้น เช่น กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญาและกฎหมายพยาน เป็นต้น แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า การที่อังกฤษนำเอากฎหมายของอังกฤษดังกล่าวมาใช้กับมุสลิมนั้นไม่ได้มีการคัดค้านจากมุสลิม นับว่าเป็นห้วงเวลาหัวต่อที่สำคัญที่แสดงให้เห็นว่า แนวความคิดกฎหมายอาณานิกร (Secular law) ได้เป็นที่ยอมรับจากผู้นำที่สำคัญของสังคมมุสลิม¹

ในปี 1772 มีผู้พิพากษาอังกฤษ 2 นายได้เข้ามาทำหน้าที่แทน Qadis ใน British India ผู้พิพากษาทั้งสองคนนี้ได้ได้รับความช่วยเหลือในเบื้องต้นจากที่ปรึกษากฎหมายอิสลาม (Jurist-Consult) หรือที่เรียกว่า Mufti ที่ได้รับการคัดเลือกจากมุสลิมผู้รอบรู้ โดยมีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของหลักกฎหมายอิสลามเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาคดี ผู้พิพากษาเหล่านี้ได้ให้คำสอนเกี่ยวกับกฎหมายอังกฤษ เช่น หลักที่ยึดถือคำพิพากษาในคดีก่อน ซึ่งถือเป็นบรรทัดฐาน (Doctrine of precedent) หลักการทั่ว ๆ ไปของ Common law และหลักแห่งความยุติธรรม (Equity) ของอังกฤษ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ค่อย ๆ ซึมซาบเข้าไปในหลักกฎหมายอิสลามที่ใช้อยู่ในอินเดียขณะนั้น กฎหมายอิสลามในอินเดียจึงได้เจริญงอกงามขึ้นในลักษณะที่มีการผสมผสานกันระหว่างกฎหมายอังกฤษกับกฎหมายอิสลาม จึงมีบางอย่างที่แตกต่างจากกฎหมายอิสลามแท้ ๆ (Pure Muslim Law) จึงเป็นเหตุให้เกิดนิติศาสตร์แนวใหม่ขึ้น เรียกว่า Anglo - Muhammadan²

¹ Ahmad ibrahim, Islamic law in Malaya, Malasian Sociological Research in stitute Ltd., (Kuala lumpur : Polygraphic press sendirian Berhad, 1975), p. 112.

² Ibid.

หลักกฎหมายแพ่ง Anglo - Muhammadan นั้นมีลักษณะเนื้อหาที่แตกต่างจากแง่มุมของอิสลาม แต่ได้นำมาใช้โดยนักนิติศาสตร์ของอังกฤษโดยบังเอิญ¹

ค. สถานการณ์ของกฎหมายอิสลามในมาเลเซีย

1. ลักษณะทั่วไปทางสังคม มาเลเซียมีโครงสร้างทางสังคมเป็นแบบพหุสังคม (Multi-Racial Social) คือสังคมที่มีหลายเชื้อชาติอยู่ร่วมกัน คือ ประกอบด้วยเชื้อชาติมาเลย์ที่นับถือศาสนาอิสลาม ประมาณ 50 % เชื้อชาติจีนที่นับถือศาสนาพุทธ ขงจื้อ คริสต์ 35 % และเชื้อชาติอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดู 10 % และเชื้อชาติอื่น ๆ อีก 5 % ตามรัฐธรรมนูญกำหนดให้ศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติ ศาสนาอิสลามนับว่ามีอิทธิพลต่อการส่งเสริมแนวความคิดทางการเมืองของผู้นำและประชาชน ตลอดจนประชาชนมาเลเซีย² มาเลเซียมีพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ คือ ในยุคอาณาจักรศรีวิชัย เป็นยุคที่ได้รับอารยธรรมจากอินเดียและยอมรับศาสนาพุทธ ต่อมาในยุคชะปาติตเป็นยุคที่ได้รับอิทธิพลของมุสลิม โดยมีพ่อค้าชาวอาหรับนำเข้ามาค้าขายในลุ่มมาตราเป็นครั้งแรกและขยายต่อมายังมาลายู

โปรตุเกสเป็นประเทศตะวันตกชาติแรกที่เข้ามามีอิทธิพลในแถบนี้ โดยเข้ามาครอบครองมะละกา และมีอิทธิพลเหนือมาลายูเพื่อใช้เป็นเส้นทางทางการค้าขาย และเพื่อเผยแพร่ศาสนาคริสต์ และต่อมาถูกฮอลันดาขับไล่ออกจากมาลายู อังกฤษได้ครอบครองอินเดียอยู่ก่อนแล้วต้องการขยายศูนย์การติดต่อการค้าขายกับจีน และเป็นการต่อต้านฝรั่งเศส จึงได้เข้ามามีอิทธิพลในแหลมมาลายู มาเลเซียได้รับเอกราชเมื่อ ปี ค.ศ. 1957³



¹ Ahmad ibrahim, Islamic law in Malaya, Malasian Sociological Research in stitute Ltd., (Kuala lumpur : Polygraphic press sendirian Berhad, 1975), p. 112.

² กระมล ทองธรรมชาติ (กัศณะ), เอเชียความรู้ทั่วไป, อ่างแล้ว, หน้า 145.

³ เรื่องเดียวกัน, หน้า 148.

2. สถานการณ์ของกฎหมายอิสลามก่อนตกเป็นอาณานิคม การขัดแย้งกัน

ระหว่างกฎหมายมุสลิมกับกฎหมายแพ่งเป็นที่ทราบกันดีในโลกมุสลิมมากกว่าศตวรรษ ความขัดแย้งเริ่มขึ้นเมื่อประเทศมุสลิมได้ตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตก กฎหมายอิสลามภายใต้การปกครองของเจ้าอาณานิคมที่นำออกมาใช้นั้นจึงประสบกับปัญหาความยุ่งยาก การใช้กฎหมายอิสลามมีจำกัดแต่เฉพาะเรื่องครอบครัวเท่านั้น ส่วนกฎหมายอิสลามสาขาอื่น ๆ เช่น กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญาต้องใช้อกฎหมายของเจ้าอาณานิคมตะวันตกแทน

ในมาเลเซียก่อนการเข้ามาของอังกฤษอยู่ภายใต้หลักกฎหมายอิสลามและกฎหมายประเพณีมาเลย์ (Malay Customary law) กฎหมายเหล่านี้ได้ถูกนำมาใช้ร่วมกัน จนกระทั่งมีกฎบัตรของอังกฤษในปี ค.ศ. 1874 พื้นฐานของกฎหมายมาเลย์นั้นมีพื้นฐานมาจากกฎหมายอิสลาม กฎหมายอิสลามก็ได้มีการยอมรับจากผู้พิพากษาในสมัยนั้น ดังคดี Ramah V. Laton ผู้พิพากษา Acton และ Thomas ได้ตัดสินว่ากฎหมายอิสลามก็คือกฎหมายของรัฐ (มาเลเซีย) และไม่ใช่มุขกฎหมายต่างประเทศ ฉะนั้น จึงจะต้องยอมรับและศาลต้องใช้อกฎหมายอิสลามในการตัดสินคดี¹

3. สถานการณ์ของกฎหมายอิสลามในระหว่างเป็นอาณานิคมของอังกฤษ

แม้ว่ากฎหมายอิสลามจะได้รับการยืนยันถึงสถานการณ์ว่าเป็นกฎหมายของรัฐก็ตาม แต่เนื่องจากอิทธิพลของเจ้าหน้าที่ผู้พิพากษา นักกฎหมายของอังกฤษทำให้กฎหมายอังกฤษเริ่มครอบงำกฎหมายอิสลามในมาเลเซีย ที่เป็นเช่นนี้มีสาเหตุมาจาก

ก. เมื่อมีการตรากฎหมายโดยสภานิติบัญญัติก็กระทำไปโดยอยู่ภายใต้อิทธิพลและคำแนะนำของอังกฤษ และบ่อยครั้งที่กฎหมายอังกฤษถูกนำมาใช้บัญญัติกฎหมาย

ข. อิทธิพลของผู้พิพากษาอังกฤษ เพราะตามระบบกฎหมายอังกฤษ (English legal System) บ่อเกิดของกฎหมาย Anglo-saxon นอกจากการนิติบัญญัติ

¹ Azizan B. Abdul Razak, Conflict Resolution : Personal laws system, Civil law system and Muslim school of law, p. 15..

(Legislation) แล้วยังมีกฎหมายที่เกิดจากคำพิพากษาของศาลและคดีบรรทัดฐาน (Cese law and precedent)¹ ดังนั้น ในกรณีนี้คดีเกิดขึ้นแต่ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ ศาลต้องใช้หลักกฎหมาย Common law เป็นหลักในการตัดสินคดี ซึ่งตามข้อเท็จจริงแล้วเพื่อความเหมาะสมในการพิจารณาคดีควรอ้างหลักกฎหมายอิสลาม แต่ก็ไม่ได้ทำเช่นนั้น เนื่องจากความไม่รู้ของผู้พิพากษา ด้วยวิธีนี้กฎหมายอังกฤษ (Common law) จึงเริ่มแพร่ขยายเป็นอย่างมากจนกลายมาเป็นรากฐานของกฎหมายมาเลเซีย หรืออีกนัยหนึ่งอาจกล่าวได้ว่า กฎหมายอิสลามได้ถูกจัดไว้อีกส่วนหนึ่งโดยปริยาย ซึ่งมีขอบเขตอำนาจพิจารณาคดีอย่างจำกัด ได้มีการตรากฎหมายครั้งแรกที่เกี่ยวกับกฎหมายอิสลามใน ปี ค.ศ. 1885 คือ The Registration of Muhammadan marriages and divorces Enactment ซึ่งใช้ในรัฐเปรัก (Perak) ต่อจากนั้นได้มีการตราพระราชบัญญัติและกฎีกาเป็นจำนวนมากเพื่อการบริหารกฎหมายอิสลามโดยนำไปใช้ทุกรัฐในมาเลเซีย²

4. สถานการณ์ของกฎหมายอิสลามในปัจจุบัน เนื่องจากอิทธิพลของกฎหมายอังกฤษในระหว่างที่เป็นอาณานิคม เมื่อมาเลเซียได้รับเอกราชจึงก่อให้เกิดปัญหาทางด้านนิติศาสตร์ติดตามมา คือ

ก. การขัดแย้งเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจศาล ระหว่างศาลศาลนา กับ ศาลแพ่ง ในปัจจุบันพระราชบัญญัติเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามทุก ๆ รัฐในมาเลเซียประกอบขึ้นด้วยกฎหมายมุสลิมที่ได้กำหนดขึ้นในระหว่างที่เป็นอาณานิคมของอังกฤษ ยิ่งไปกว่านั้นบทบัญญัติของกฎหมายอิสลามในมาเลเซียโดยเฉพาะในเนื้อหาของกฎหมายครอบครัว (Family law) เช่น การสมรส การหย่า ค่าเลี้ยงดู ความปกครอง มรดก การให้ การบริจาคน และข้อกำหนดบางอย่างที่เป็นความผิดทางศาลนามีรากฐานมาจากกฎหมายอิสลามในระหว่างที่เป็นอาณานิคม

¹ ดู วิจิต มั่นตาภรณ์, กฎหมายแองโกล-แขกขึ้น, เอกสารประกอบการบรรยายกฎหมายแองโกล-แขกขึ้น, ชั้นปริญญาโท, ปีการศึกษา 2524, คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า 35.

² Azizan B. Abdul Razak, Conflict Resolution : Persoal Laws System, civil law system and Muslim School of law, p. 16.

จากการตรากฎหมายในรูปแบบพระราชบัญญัติอย่างตะวันตก และการนำเอาระบบศาลทางอาณาจักรมาใช้ ทำให้กฎหมายอิสลามต้องบริหารโดยศาลพิเศษ คือ Qadi Court ซึ่งมีขอบเขตอำนาจศาลเฉพาะที่เกี่ยวกับศาลนอกระบบเดียว ซึ่งเกิดความขัดแย้งเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจศาล ระหว่างศาลศาลนอกระบบกับศาลอาณาจักร คือ High Court¹ จากข้อโต้แย้งเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจพิจารณาคดีของศาล High Court กับ Qadi Court เป็นผลจากความขัดแย้ง ระหว่างนิติศาสตร์ 2 แบบ ในดินแดนเดียว คือ ระบบกฎหมายอิสลามกับระบบกฎหมายแห่งชาติ (Islamic and National legal system) ในทางทฤษฎีการบริหารกฎหมายอิสลามควรกระทำโดยศาลศาลนอกระบบ (Shariah Court) ไม่ใช่ศาลทางฝ่ายอาณาจักร (Secular Court) แต่ในทางปฏิบัติ ศาลสูง (High Court) ยังคงมีสิทธิที่จะแย้งคำตัดสินของ Qadi Court บทบัญญัติตามพระราชบัญญัติกฎหมายอิสลามบางรัฐได้กำหนดว่า ในกรณีที่เกิดความแตกต่างหรือความขัดแย้งกันเกิดขึ้นระหว่างศาลสูงกับศาลศาลนอกระบบ คำตัดสินของศาลแพ่งซึ่งได้พิจารณาภายในขอบเขตอำนาจศาลนั้นต้องถือตามคำตัดสินของศาลแพ่ง²

ข. ความขัดแย้งระหว่างกฎหมายอิสลามกับกฎหมายประเพณี (Adat law) ในบางรัฐของมาเลเซีย กฎหมายประเพณีมีสถานะเช่นเดียวกับกฎหมายอิสลาม ดังเช่นกรณีของรัฐ Negeri Sembilan ซึ่งได้กำหนดกรณีนี้เอาไว้โดยเฉพาะ เช่น กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการรับมรดกที่ดินโดยการลำกัตทายาทที่เป็นหญิง แต่ทว่า บางกรณีอาจได้รับประโยชน์ภายใต้เงื่อนไขบางประการ ซึ่งบทบัญญัติเช่นนี้นับว่าขัดกับหลักกฎหมายอิสลาม³

ค. ความขัดแย้งเกี่ยวกับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติกฎหมายอิสลามตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติกฎหมายอิสลามในบางกรณีไม่ได้ประมวลในเรื่องที่เป็นสาระสำคัญของกฎหมายอิสลามเอาไว้ Qadi จึงมีความเป็นอิสระอย่างเต็มที่ที่จะอ้างถึงคำสอนต่าง ๆ

¹ Azizan B. Abdul Razak, Conflict Resolution : Personal Laws System, civil law system and Muslim School of law, p. 17.

² Ibid.

³ Ibid.

ของสำนักชาฟีอี (Shafie) จากที่มาตามที่เขาคัดค้าน สิ่งที่เป็นที่แน่นอนว่า จะต้องเกิดปัญหาทางด้านนิติศาสตร์บางประการที่ประชาชนจะต้องค้นหาความถูกต้องแน่นอนของบทบัญญัติสำหรับบางกรณี ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายแพ่งที่ใช้ในกรณีเดียวกันตามกฎหมายว่าด้วย การสมัครและ การหย่าของผู้ไม่ใช่มุสลิม¹.

มติที่ขัดแย้งกันระหว่างกฎหมายอิสลามกับกฎหมายแพ่งในมาเลเซีย ปัจจุบันได้ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งเหล่านี้²

ง. สถานการณ์ของกฎหมายอิสลามในสิงคโปร์

1. ลักษณะทางสังคม สิงคโปร์มีลักษณะเป็นพหุสังคมที่มีหลายเชื้อชาติอยู่ร่วมกัน มีภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างกัน ดังนั้น คำสอนที่ประชาชนนับถือจึงมีหลายคำสอน แต่เนื่องจากหลักการของรัฐธรรมนูญไม่ยึดถือคำสอนใดคำสอนหนึ่ง เป็นคำสอนประจำชาติ (Secular state) คำสอนทุกคำสอนจึงได้รับการสนับสนุนและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน³

สิงคโปร์ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษเช่นเดียวกับมาเลเซียเมื่อได้รับเอกราชจากอังกฤษ จึงเข้าเป็นสหพันธ์มาลายา และต่อมา ในปี ค.ศ. 1965 จึงได้แยกตัวเป็นเอกราชอันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางเชื้อชาติ เศรษฐกิจ การเมือง⁴

2. สถานการณ์ของกฎหมายอิสลามในระหว่างเป็นอาณานิคม แม้สิงคโปร์จะได้แยกตัวออกมาจากมาเลเซียแล้วก็ตาม แต่ก็มีประชาชนส่วนหนึ่งที่เป็นมาเลย์ ประมาณ 14.6 % ซึ่งเดิมก่อนตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกในแหลมมาลายู (Malay Peninsula) ได้ยอมรับ

¹ Azizan B. Abdul Razak, Conflict Resolution : Personal Laws System, civil law system and Muslim School of law, p. 17.

² Ibid. p. 18.

³ กระมล ทองธรรมชาติ (กับคณะ), เอเชียความรู้ทั่วไป, อังแล้ว, หน้า 215.

⁴ เรื่องเดียวกัน, หน้า 151.

หลักกฎหมายคำสอนในการตัดสินคดีแพ่งทั้งหมด¹ เมื่อตกเป็นอาณานิคมของ อังกฤษร่วมกับ มาเลเซียแล้ว สิงคโปร์ก็ได้รับมรดกทางกฎหมาย Common law ของอังกฤษร่วมกับมาเลเซีย ตาม Charter of Justice of 1855 ซึ่งต้องนำเอากฎหมายอังกฤษมาใช้กับทุกคนทั้งชาว สิงคโปร์และชาวพื้นเมือง เฉพาะที่เกี่ยวกับเนื้อหาทางคำสอนและประเพณีของชาวพื้นเมือง เท่านั้นที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องใช้กฎหมายอังกฤษ²

3. สถานการณ์ของกฎหมายอิสลามหลังจากได้รับเอกราช เมื่อสิงคโปร์ได้ แยกตัวมาจากมาเลเซียแล้ว ได้ตราพระราชบัญญัติ Administration of muslim law Act ขึ้นใช้บังคับกับมุสลิมใน ปี ค.ศ. 1966

จ. สถานการณ์ของกฎหมายอิสลามในอินโดนีเซีย

คำสอนอิสลามได้เข้ามายังหมู่เกาะอินโดนีเซียในศตวรรษที่ 13 โดยพ่อค้าชาวเปอร์เซีย นำเอาคำสอนอิสลามมาเผยแพร่ จึงเกิดอาณาจักรอิสลามแห่งแรกในชวากลาง และได้ขยายไป ทั่วหมู่เกาะอินโดนีเซียในเวลาต่อมา

ภายหลังจากการจากไปของโปรตุเกส สเปนก็เข้ามาสู่อินโดนีเซีย ดัชท์ก็ได้เข้ามา ในต้นศตวรรษที่ 17 โดยเข้ามาในเมืองปัตตาเวียเป็นแห่งแรก ต่อมาในศตวรรษที่ 17 ดัชท์ ก็สามารถปกครองอินโดนีเซียได้ทั้งหมด³

1. สถานการณ์ของกฎหมายอิสลามในระหว่างที่เป็นอาณานิคม กว่า 3 ศตวรรษที่อินโดนีเซียตกเป็นอาณานิคมของชาติดัตช์ตะวันตก ตลอดระยะเวลาที่เป็นอาณานิคมของ ชาติดัตช์ตะวันตก ตลอดระยะเวลาที่เป็นอาณานิคมได้มีการเป็นปรกัมภ์ต่อกันระหว่างผู้ปกครองกับ

¹ Datu michael O. Mastura, Adminitration of muslim personal law System in Muslim-minority courtty, 1st Asean shariah administrators conference workshop, August 7-11, 1983, Manila Philippines, p. 4.

² Ibid. p. 6.

³ กระมล ทองธรรมชาติ (กับคณะ), เอเชียความรู้ทั่วไป, อ่างแล้ว, หน้า 244.

ผู้นำทางศาสนาอิสลามมาโดยตลอด ซึ่งรวมถึงความขัดแย้งในทางด้านการใช้กฎหมายอิสลามอันสืบเนื่องมาจากท่าทีที่ไม่ยอมรับกฎหมายอิสลามของผู้ปกครอง และการที่จะพยายามกีดกันชาติตะวันตกไม่ให้แทรกแซงการใช้กฎหมายอิสลาม รัฐบาลในระหว่างที่เป็นอาณานิคมนั้นไม่ได้เอาใจใส่ต่อศาลศาสนาอิสลาม (Islamic Court) และในบางครั้งถึงกับยกเลิกศาลศาสนาอิสลามเมื่อสิ้นสุดระบอบการปกครองแบบอาณานิคมแล้วจึงเหลือศาลศาสนา (Shariah Court) หรือในขณะนั้นเจ้าอาณานิคมเรียกว่า priests-Court บนเกาะชวา มาตุลา (Madura) และบางส่วนของ South kalimantan เท่านั้น¹ อย่างไรก็ตาม ศาลเหล่านี้ก็ยังขาดวิธีการดำเนินการทางศาล (Court-Proceddure) เท่าที่เหมาะสม และขาดการจัดการทางศาลที่ดี ซึ่งนับว่าไม่มีคุณลักษณะเหมือนกับศาลโดยทั่วไป

จากการเป็นปรกักษ์กันทั้งสองฝ่าย คือ ผู้ปกครองของอาณานิคมกับประชาชนมุสลิม ไม่ได้ก่อประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่าย คือ รัฐบาลไม่อาจเข้ามามีส่วนร่วมกับผู้นำทางศาสนา โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการส่งเสริมกฎหมายอิสลาม และมุสลิมส่วนมากไม่ได้ประโยชน์จากท่าทีที่พยายามแยกตัวออกห่าง (Isolationism) และกีดกันเจ้าอาณานิคมไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมซึ่งทำให้การพัฒนาเป็นไปโดยไม่ทั่วถึง ข้างยังถูกคุกคามจากเจ้าอาณานิคมด้วยซ้ำ²

2. สถานการณ์ของกฎหมายอิสลามภายใต้การปกครองของอินโดนีเซีย หลังจากอินโดนีเซียได้รับเอกราชและมีรัฐบาลแห่งชาติทำการปกครองประเทศตามหลักปรัชญาศีล (Pancasila) ตามรัฐธรรมนูญปี ค.ศ. 1945³ รัฐบาลได้ตอบสนองความต้องการของมุสลิมในกรณีที่เกี่ยวข้อง

¹ Bustanal Aririn, The Administration of Shariah law in Indonesia, 1st Asian shariah administrators conference workshop August 7-11, 1983, Manila Philippines, p. 5.

² Ibid. p. 6.

³ หลักปรัชญาศีลปรากฏอยู่ในอารัมภบทของรัฐธรรมนูญฉบับ ค.ศ. 1945 ถือว่าเป็นหลักปรัชญาของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้ คือ (1) เชื่อในพระผู้เป็นเจ้า (2) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของอินโดนีเซีย (3) การตกลงร่วมกันโดยอาศัยการศึกษาหารือกัน (4) ความเป็นธรรมในสังคม และ (5) ความเป็นมนุษย์ชาติที่เจริญและเป็นธรรม

กฎหมายอิสลาม และโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับศาลคำสอนทำให้อินโดนีเซียมีระบบกฎหมายเพียงระบบเดียว คือ ระบบกฎหมายแห่งชาติ (National law System) โดยการประมวลและรวบรวมกฎหมายหลาย ๆ อย่างในทุก ๆ แห่งเข้าด้วยกันขึ้นเป็นหลักการแห่งหมู่เกาะในเนื้อหาของกฎหมาย (Archipelago principal) ซึ่งชาวอินโดนีเซียเรียกว่า Wawasan Nusantara กฎหมายอิสลามก็เป็นส่วนประกอบของระบบกฎหมายแห่งชาติ ศาลคำสอนก็อยู่ภายใต้ระบบศาลแห่งชาติ (National court system) ดังนั้น ผู้พิพากษาทั้งหมดในอินโดนีเซียก็คือผู้พิพากษาของรัฐ ซึ่งต้องมีวิธีการแต่งตั้งและปฏิกิริยาตอบสนองเหมือนกันหมด จะแตกต่างกันก็แต่เฉพาะแต่เขตอำนาจในการพิจารณาตัดสินเท่านั้น ไม่มีทำที่เป็นปฏิกิริยาต่อกฎหมายอิสลามจากรัฐบาล และในขณะเดียวกันก็ไม่มีทำที่แยกตัวโดดเดี่ยว และกีดกันจากผู้นำทางคำสอนปรากฏให้เห็น¹

3. วิวัฒนาการศาลคำสอนอิสลาม ตลอดระยะเวลาที่ตกเป็นอาณานิคมได้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพของกฎหมายอิสลาม ตลอดจนเขตอำนาจการพิจารณาตัดสินของศาลคำสอนอิสลามมาโดยลำดับ ซึ่งเป็นผลมาจากการที่เจ้าอาณานิคมได้นำเอาระบบกฎหมายที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองมากที่สุด เพื่อลุ่มง่หยาบและผลประโยชน์ของเจ้าอาณานิคม คือ ระบบกฎหมายดัตช์ (Dutch legal system) ดังนั้น ระบบกฎหมายของอินโดนีเซียก่อน ปี ค.ศ. 1882 จึงมีลักษณะเป็น Complexu Doctrine คือ เป็นระบบกฎหมายสองระบบซ้อนกัน กล่าวคือ แม้เจ้าอาณานิคมจะนำเอาระบบกฎหมายของตนเอง คือ Dutch legal system หรือระบบกฎหมายภาคพื้นยุโรปมาบังคับใช้ในอินโดนีเซียก็ตาม แต่ก็ต้องนำเอาระบบกฎหมายอิสลามมาบังคับใช้เช่นกัน นักนิติศาสตร์ชาวดัตช์ชื่อ L.W.C. Van den Berg เป็นผู้นำเอาแนวความคิดของลัทธิ Complexu มาใช้ในอินโดนีเซียได้กล่าวว่า กฎหมายอิสลามต้องนำไปใช้กับมุสลิม เพราะพวกเขาได้ยึดมั่นศรัทธาในหลักการคำสอนของพวกเขา²

แต่ต่อมาเมื่อเจ้าอาณานิคมต้องการจะปกครองอาณานิคมของตนเองอย่างเข้มงวดยิ่งขึ้น แนวความคิดของลัทธิ Complexu จึงเป็นสิ่งที่ล้าสมัย ดัตช์จึงได้นำเอาทฤษฎีการรวม

¹Bustanul Arifin, Administration of Shariah law in Indonesia, pp. 6, 7.

²Ibid. p. 8.

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน(Unification theory) มาใช้ ซึ่งก็หมายความว่า ดัชท์ได้นำเอา
ระบบกฎหมายของตนเอง คือ ระบบกฎหมายดัชท์เพียงอย่างเดียวมาใช้กับประชาชนชาว
อินโดนีเซีย

จากนโยบายนี้ได้รับการคัดค้านจากผู้เชี่ยวชาญชาวดัชท์ ชื่อ Van Vollenhoven
ผู้ซึ่งนำเอาระบบกฎหมายประเพณี (Adat law system) มาใช้ ระบบกฎหมายประเพณีนี้ได้
ขัดแย้งกับทฤษฎีการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (Unification theory) โดยเห็นว่าทฤษฎี
แห่งการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นสิ่งที่ไม่มีความเป็นธรรมชาติ ทั้งยังไม่สอดคล้องกับ
สภาพสังคมของประชาชนอินโดนีเซีย เพราะทุก ๆ สังคมย่อมจะต้องมีระบบกฎหมายเป็นของ
ตนเอง ซึ่งได้กำหนดถึงความสัมพันธ์ของเอกชนระหว่างสมาชิกของสังคมเอาไว้ และกฎหมาย
ประเพณีก็ได้ฝังรากลึกติดพันอยู่กับประเพณีค่านิยมของสังคม ฉะนั้น กฎหมายประเพณี (Adat
law) เท่านั้นที่จะมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสังคม การนำระบบกฎหมายอื่นมาใช้จึงมักจะ
ถูกปฏิเสธและถือว่าเป็นอันตรายต่อความปรองดองในสังคม¹ จากแนวความคิดนี้ทำให้นัก
กฎหมายฝ่ายประเพณีขัดแย้งกับแผนการที่จะนำเอาระบบกฎหมายดัชท์เพียงระบบเดียวมาใช้
ของเจ้าอาณานิคม นอกจากนี้กฎหมายประเพณีก็ขัดแย้งกับกฎหมายอิสลาม ซึ่งกฎหมายอิสลาม
เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ใช้ได้ และบางส่วนก็ใช้กฎหมายประเพณี ฉะนั้น การดิ้นรนต่อสู้ทาง
การเมืองเกี่ยวกับกฎหมายในระหว่างที่เป็นอาณานิคม จึงมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยม (Triangular
Struggle) คือระบบกฎหมาย 3 ระบบ กฎหมายตะวันตก กฎหมายประเพณีและกฎหมาย
อิสลาม²

ในปี ค.ศ. 1882 รัฐบาลอาณานิคมได้ออกกฤษฎีกาเกี่ยวกับศาลศาสนาอิสลาม แต่
กฤษฎีกาลฉบับนี้ไม่ได้กำหนดขอบเขตอำนาจการพิจารณาคดีของศาลศาสนาอิสลาม เพียงแต่
กำหนดโครงสร้างของศาลศาสนาเท่านั้น เช่น กำหนดให้ศาลศาสนาอิสลามประกอบด้วย
ประชาชน 1 คน ผู้พิพากษา 2 คนและมียนายทะเบียน 1 คน โดยทั้งหมดได้รับเงินช่วยเหลือ

¹Bustanul Arifin, Administration of Shariah law in Indonesia,
p. 9.

²Ibid.

จากรัฐบาล ฉะนั้น เขตอำนาจการพิจารณาคดีของศาลศาสนาอิสลาม จึงยังคงเหมือนเดิมเช่น
ที่ใช้อยู่ก่อนปี ค.ศ. 1882¹

ในปี ค.ศ. 1922 รัฐบาลอาณานิคมได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อหาแนวทางสร้างศาล
ศาสนาอิสลามให้ดีขึ้นกว่าเดิม และในที่สุดคณะกรรมการก็ได้ลงมติไว้ 4 ประการ ดังนี้

3.1 คดีที่อยู่ในเขตอำนาจการพิจารณาคดีของศาลศาสนาอิสลามนั้นจะ
ต้องเป็นคดีที่ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับมุสลิม ซึ่งไม่ว่าจะแยกออก
ต่างหากจากกฎหมายอิสลามได้ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายการแต่งงาน การหย่า ของหมั้น
(Mahar) และหนี้ของสามีที่จะต้องชำระเป็นค่าเลี้ยงดู (Alimony) แก่ภรรยาเมื่อหย่าจากกัน

3.2 ศาลศาสนาอิสลามซึ่งแต่ก่อนประกอบด้วยประธานและองค์คณะอีก
2 นาย ในอนาคตควรจะมีองค์คณะ ประกอบด้วยผู้พิพากษา 1 นาย ซึ่งมิอาจมีหน้าที่เช่นเดียวกับ
กับ Qadi ผู้พิพากษานี้จะได้รับความช่วยเหลือจากที่ปรึกษา 2 นาย ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
กฎหมายอิสลาม

3.3 ผู้พิพากษาศาลศาสนาต้องได้รับเงินยังชีพจากรัฐบาล

3.4 ต้องมีการก่อตั้งศาลอุทธรณ์ขึ้นเพื่อทบทวนคำพิพากษาหรือกระบวนการ
การพิจารณาใหม่อีกครั้งในทุกคดีของศาลศาสนาอิสลาม

จากมติของคณะกรรมการดังกล่าว ในปี ค.ศ. 1931 ได้มีกฎหมายว่าด้วยศาลศาสนา
อิสลาม ซึ่งตอนนั้นเรียกว่า Priest-court แต่เมื่อได้ขจัดออกไปจากอินโดนีเซีย กฎีกา
ฉบับนี้ก็มิอาจมีผลบังคับได้ เนื่องจากประสบปัญหาทางการเงิน ในปี ค.ศ. 1937 ได้มี
กฎหมายกำหนดเขตอำนาจการพิจารณาคดีของศาลศาสนาอิสลามเอาไว้ ซึ่งมีอำนาจพิจารณาคดี
เฉพาะคดีที่เป็นข้อโต้แย้งในการสมรสระหว่างคู่สมรสเท่านั้น และได้กำหนดว่า คำตัดสินของ
ศาลศาสนาอิสลามมิอาจมีผลบังคับตัวเอง แต่ต้องอาศัยการกระทำเป็นคำสั่งของศาลธรรมดา
ซึ่งแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างศาลธรรมดาและศาลศาสนา² โดยศาลศาสนามีอำนาจ
เฉพาะพิจารณาคดี ส่วนคำตัดสินนั้นต้องกระทำในนามของศาลธรรมดา

¹Bustanul Arifin, Administration of Shariah law in Indonesia,
p. 10.

²Ibid. p. 12.

เมื่อดัตช์และญี่ปุ่นได้ออกไปจากอินโดนีเซีย สถานภาพของศาลคำสอนอิสลามก็คงไม่มีการเปลี่ยนแปลง ภายหลังจากการปฏิวัติในอินโดนีเซีย แนวความคิดเกี่ยวกับศาลคำสอนอิสลามยังคงสืบเนื่องต่อไป และได้รับการพัฒนาทั้งจากรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซียและผู้นำคำสอนอิสลาม และในปี ค.ศ. 1957 รัฐบาลได้ออกกฤษฎีกาฉบับที่ 45 โดยกำหนดให้ก่อตั้งศาลคำสอนอิสลามขึ้นทุก ๆ ภูมิภาค และยังได้เพิ่มอำนาจการพิจารณาคดีของศาลคำสอนอิสลามขึ้นอีก ซึ่งแต่เดิมศาลคำสอนอิสลามมีอำนาจพิจารณาคดีเฉพาะแต่คดีข้อโต้แย้ง เกี่ยวกับการล้มรลเท่านั้น แต่ตามกฤษฎีกาฉบับนี้ ศาลคำสอนอิสลามมีอำนาจพิจารณาคดี นอกจากคดีข้อโต้แย้ง เกี่ยวกับการล้มรลแล้วยังมีอำนาจพิจารณาคดีเกี่ยวกับการรับมรดกโดยมีพินัยกรรม (Legacy) การเป็นผู้ปกครองเด็ก (Hadanah) การบริจาคทานเพื่อชุมชน (Wagaf) การบริจาคทานโดยสมัครใจ (Sodagah)¹

ในปี ค.ศ. 1970 ได้มีกฤษฎีกาฉบับที่ 14/1970 กฤษฎีกาฉบับนี้เป็นการปรับปรุงแก้ไขมาจากกฤษฎีกาฉบับที่ 19/1964 ซึ่งนับว่ากฤษฎีกาฉบับนี้เป็นพื้นฐานของข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับศาลคำสอนอิสลามในเวลาต่อมา กฤษฎีกาฉบับนี้ได้กำหนดให้ศาลมี 4 สาขา คือ ศาลทั่วไป ศาลทหาร ศาลคำสอนอิสลามและศาลปกครอง โดยมี Supreme court เป็นศาลสูงสุด²

จ. สถานภาพของกฎหมายอิสลามในฟิลิปปินส์

1. ลักษณะทั่วไปทางสังคมของฟิลิปปินส์ ฟิลิปปินส์ประกอบไปด้วยหมู่เกาะต่าง ๆ ถึง 7,107 มีประชากรนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 83 % นิกายโปรเตสแตนต์ 9 % และพวกที่นับถือศาสนาอิสลามประมาณ 7.5 ล้านคน ซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนเกาะมินดาเนา พวกมุสลิมถือว่า พวกฟิลิปปินส์ที่นับถือศาสนาคริสต์เป็นพวกจักรวรรดินิยมที่เข้ามาขยายอิทธิพลในดินแดนแถบนี้ ดังนั้น สิ่งต้องขับไล่พวกนี้ออกไป ในแถบตอนใต้ของหมู่เกาะฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่เป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ พวกคริสต์จึงนิยมอพยพไปทำมาหากินมากขึ้น ยิ่งเป็นเหตุให้มุสลิมไม่พอใจ นอกจากนั้นระบบการบริหารและราชการที่ควบคุมโดยรัฐบาลกลางก็เข้าข้างพวกคริสต์

¹ Bustanul Arifin, Administration of Shariah law in Indonesia, p. 13.

² Ibid. p. 14.

พอใจ นอกจากนั้นระบบการบริหารและราชการที่ควบคุมโดยรัฐบาลกลางก็เข้าข้างพวกคริสต์ ทำให้พวกมุสลิมเห็นว่าพวกตนถูกกีดกันทางการเมือง¹ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ติดตามมา ทำให้รัฐบาลพยายามเข้าคลี่คลายปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในหมู่เกาะภาคใต้

2. สถานการณ์ของกฎหมายอิสลามก่อนยุคล่าอาณานิคม เมื่อพ่อค้าชาวอาหรับ ได้เดินทางมาค้าขายโดยทางทะเลจากมหาสมุทรอินเดีย อินโดนีเซีย จนถึงหมู่เกาะมินดาเนา และหมู่เกาะลูซอน เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าชาวอาหรับที่ทำการค้านั้น นอกจากจะทำการค้าขาย กับคนพื้นเมืองแล้วยังนำเอาคำสอนอิสลามมาเผยแพร่แก่ผู้คนตามเกาะต่าง ๆ และคนพื้นเมือง ก็เริ่มทยอยนับถือคำสอนอิสลามอย่างกว้างขวาง ในที่สุดหมู่เกาะมินดาเนาก็กลายเป็นดินแดน แห่งอิสลาม-กฎหมายอิสลาม

การปกครองในสมัยก่อนการเข้ามาของลัทธิล่าอาณานิคมนั้นมีรูปแบบการปกครอง แบบแว่นแคว้น โดยมีผู้ลัษฏานแต่ละแว่นแคว้นทำการปกครองภายในแว่นแคว้นของตัวเอง การ ตัดสินคดีต้องใช้กฎหมายอิสลามเป็นแนวทางในการตัดสินคดี เพราะประชากรส่วนใหญ่นับถือ คำสอนอิสลาม กฎหมายอิสลามจึงมีสถานะเป็นกฎหมายแห่งแว่นแคว้น เช่น ผู้ลัษฏาน Kudarat แห่งเมือง Magindanao ได้ประกาศใช้ประมวลกฎหมายอิสลามที่เรียกว่า Luwaran of Magindanao ในปี ค.ศ. 1886 กฎหมายฉบับนี้เป็นการรวบรวมหลักกฎหมายต่าง ๆ ที่สำคัญ จากสำนักกฎหมายชาฟีอี และในปี ค.ศ. 1878 ผู้ลัษฏาน Pulalun แห่งเมือง Sulu ได้ประกาศ ใช้ประมวลกฎหมายบุคคล (Principal personal law Codex) ชื่อ diwan โดยมี Agama Court เป็นผู้ใช้ทั้งกฎหมาย Luwaran และ Diwan²

ในปี ค.ศ. 1902 ผู้ลัษฏาน Jamalul kiram II ได้ประกาศใช้ประมวลกฎหมาย ชูลูใหม่ (New Sulu Code)

¹ กระมล ทองธรรมชาติ (กับคณะ), เอเชียความรุ้ทั่วไป, อ่างแล้ว, หน้า 198.

² Datu Michael O. Mastura, Introduction Code of Muslim Personal Laws of Philippines (Presidential Decree NO. 1083).

3. สถานการณ์ของกฎหมายอิสลามในระหว่างที่เป็นอาณานิคม ฟิลิปปินส์ใน

ระหว่างที่ตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกก่อให้เกิดผลกระทบกระเทือนต่อสถานการณ์ของกฎหมายอิสลามที่ใช้อยู่ในฟิลิปปินส์เป็นอย่างมาก กล่าวคือ มูลเหตุที่ชาติตะวันตกต้องแสวงหาอาณานิคม เพื่อจะแสวงหาทรัพยากรแล้วยังมีมูลเหตุเพื่อการเผยแผ่คริสต์ศาสนา¹ ดังนั้น เมื่อสเปน ได้ทำการยึดฟิลิปปินส์เป็นอาณานิคมได้แล้วจึงพยายามบีบบังคับให้ชาวฟิลิปปินส์หันไปนับถือศาสนา คริสต์ สเปนจัดการปกครองหมู่เกาะฟิลิปปินส์เสมือนเป็นคำสั่งกรซึ่งจะต้องให้พลเมือง เข้ารีต ให้หมด และรัฐบาลของอาณานิคมจะต้องดำเนินการให้เป็นทีพอใจส่งหมายยกเลิก² จึงนับ ได้ว่าฟิลิปปินส์เป็นกรณีแรกที่ประเทศแรกในภูมิภาคนี้³

แต่อย่างไรก็ตามเฉพาะในภาคใต้ของหมู่เกาะที่มีมุสลิมอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น เท่านั้น ที่เจ้าอาณานิคมไม่อาจจะขยายอิทธิพลไปปกครองได้⁴ แม้จะพยายามใช้กำลังปราบปราม หลายครั้งก็ไม่สำเร็จ ในที่สุดสเปนจึงต้องทำสัญญาสันติภาพกับสุลต่านแห่ง เมืองซูลู ในปี ค.ศ. 1850 ซึ่งสุลต่านก็ยอมรับอำนาจของสเปนในฟิลิปปินส์⁵

ผลจากการตกเป็นอาณานิคมของประเทศตะวันตกจึงส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ของ กฎหมายอิสลามเป็นอย่างมาก อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากนโยบายเผยแผ่คริสต์ศาสนา ทำให้มี การทำลายล้างวัฒนธรรมเก่าอิสลาม มุสลิมจึงต้องถอยร่นเข้าสู่หมู่เกาะทางภาคใต้ ทำให้ กฎหมายอิสลามใช้อยู่แต่เฉพาะในหมู่เกาะทางภาคใต้เท่านั้น ดังจะเห็นได้จากสุลต่านต่าง ๆ ที่ได้ประกาศใช้กฎหมายอิสลามในเขตการปกครองของตน และกฎหมายอิสลามเหล่านี้ได้กลาย

¹ เจริญ ไชยชนะ, ประวัติศาสตร์ประเทศไทย (กรุงเทพฯ : เทมบรรณกิจ, 2515), หน้า 2.

² เรื่องเดียวกัน, หน้า 47.

³ ชัยโชค จุลศิริวงศ์, ปัญหามุสลิมในฟิลิปปินส์, มติชนรายวัน ฉบับวันที่ 3 มีนาคม 2525.

⁴ กระมล ทองธรรมชาติ (กัณณะ), เอเชียความรู้ทั่วไป, อ่างแล้ว, หน้า 187.

⁵ เจริญ ไชยชนะ, ประวัติศาสตร์ประเทศไทยในเอเชีย, อ่างแล้ว, หน้า 52.

มาเป็นรากฐานของกฎหมายอิสลามที่ใช้อยู่ในฟิลิปปินส์ปัจจุบัน และต่อมาฟิลิปปินส์ตกอยู่ภายใต้การปกครองของอเมริกา โดยได้รับโอนฟิลิปปินส์จากสเปน ในปี ค.ศ. 1898 ก็ได้มีพระราชบัญญัติฉบับที่ 787 เกี่ยวกับกฎหมายประเพณีของโมโร (Moro customary law)¹ ในปี ค.ศ. 1903 และ ในปี ค.ศ. 1915 ได้มีพระราชบัญญัติฉบับที่ 2520 เกี่ยวกับการใช้กฎหมายมุสลิมและประเพณี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า แม้รัฐบาลอาณานิคมก็ต้องยอมรับการคงอยู่ของกฎหมายอิสลามในฐานะที่เป็นกฎหมายประเพณีที่ใช้กันในหมู่ประชาชนมุสลิม

4. สถานการณ์ของกฎหมายอิสลามในปัจจุบัน เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองที่รัฐบาลฟิลิปปินส์กำลังเผชิญหน้าอยู่ขณะนี้ คือ ปัญหามุสลิมซึ่งมีสาเหตุมาจากทางแยกอะมินดาเนาที่มีประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามประมาณ 40 % ไม่มีที่ทำกินเนื่องจากถูกพวกคริสต์แย่งที่ทำกิน นอกจากนั้นจะมีปัญหาจากเรื่องศาสนา เรื่องแยกดินแดนการก่อการร้าย จนกระทั่งมีการจัดตั้งขบวนการเพื่อการแยกมินดาเนาออกไปตั้งประเทศใหม่² ซึ่งปัญหาเหล่านี้รัฐบาลได้พยายามแก้ไขมาโดยตลอด แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร สำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้รัฐบาลได้ใช้กำลังทหารเข้าปราบปรามและใช้แนวทางการเมือง³ นอกจากนั้นประมวลกฎหมายแพ่งมุสลิมก็เป็นหนึ่งในแผนการสำหรับการปรับปรุงและพัฒนามินดาเนาและซูลู⁴ โดยถือว่าการประมวลกฎหมายแพ่งมุสลิมเป็นผลมาจากการปรับยุทธศาสตร์ของกองกำลัง

¹ สเปเนเข้าใจว่าผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในฟิลิปปินส์ คือ พวกมัวร์ (Moors) ที่อยู่ในสเปนซึ่งเรียกมุสลิมฟิลิปปินส์ว่า มัวร์ ต่อมาแผลงเป็นโมโร (Moro)

² ถนอม อานามวัฒน์, ประวัติศาสตร์และการวิเคราะห์เอเชียปัจจุบัน (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์อักษรพิทยฯ, 2526), หน้า 274.

³ เรื่องเดียวกัน, หน้า 275 ประธานาธิบดีมาคอรส์ให้มีการลงมติว่า 13 จังหวัดภาคใต้ของเกาะมินดาเนาว่า ต้องการปกครองตนเองหรือไม่ ในปี ค.ศ. 1977 และปลายปี ค.ศ. 1978 รัฐบาลก็ส่งกำลังทหารขนาดใหญ่เข้าปราบปรามแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ

⁴ ดู Romulo M. Espaldon, Foreword, Code of Muslim Personal laws of the Philippines.

ปฏิบัติการเพื่อการปรับปรุงและพัฒนามินดาเนา (Presidential Task Force for reconstruction and development of Mindanao) เพื่อเป็นการสอดคล้องกับสังคมวิทยาทางการเมือง (Socio-political) ในขณะที่สถานการณ์ล่อแหลม¹

ในที่สุดรัฐบาลก็ได้ประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งมุสลิม (Code of Muslim Personal laws of Philippines) ในปี ค.ศ. 1977 ตามกฤษฎีกาฉบับที่ 1083 (Presidential Decree NO. 1809) นับจากที่ประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งมุสลิม ประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามในแถบมินดาเนาภายใต้ประมวลกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งร่างขึ้นอย่างเป็นระบบ

5. การประมวลกฎหมายอิสลามของฟิลิปปินส์ การประมวลกฎหมายอิสลามในฟิลิปปินส์เริ่มแรกเกิดขึ้นในเกาะซูลู ซึ่งอยู่ระหว่างการปกครองแบบสุลต่าน (Suzerain Authority) ได้มีการประมวลกฎหมายอิสลามขึ้นชื่อ Diwan Taosug และในเกาะมินดาเนา ก็ได้ประมวลกฎหมายอิสลามที่เรียกว่า Luwaran sa Magindanao โดยการรวบรวมคำอธิบายมาจากสำนักกฎหมายชาฟีอี (Shafie madhab) โดยมีศาล Agama Court เป็นผู้พิจารณาพิพากษาคดี Agama Court เป็นระบบศาลหนึ่งที่ขึ้นอยู่กับภาคใต้ของฟิลิปปินส์ ต่อมาเมื่อได้มีการรวมหลักกฎหมายอิสลามเกี่ยวกับการสมรสเอาไว้เป็นบทบัญญัติโดยเฉพาะในประมวลกฎหมายแพ่งฉบับใหม่ของฟิลิปปินส์ และบทบัญญัติเกี่ยวกับการหย่าของมุสลิมได้รวบรวมเอาไว้ตาม Republic Act NO. 1083) หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ Code of Muslim Personal laws of Philippines ซึ่งมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน ฉะนั้น เมื่อประกาศใช้ประมวลกฎหมายดังกล่าว หลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้กฎหมายอิสลามก็ต้องบังคับตามประมวลกฎหมายฉบับนี้²

¹ Romulo M. Espaldon; (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการศาสนา) คำปรารภในการจัดพิมพ์ประมวลกฎหมายสถานภาพบุคคลมุสลิมฟิลิปปินส์.

² Dutu Michael O. Mastura, Introduction, Code of muslim personal laws of Philippines (Presidential Decree NO. 1083).



สำหรับการร่างประมวลกฎหมายฉบับดังกล่าวได้แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ในระยะที่ 1 ได้ก่อตั้งคณะกรรมการวิจัยเพื่อโครงการประมวลกฎหมายอิสลาม (The Research staff for the codification of Philippines muslim laws) ตาม Memorandum Order NO. 370 โดยคณะกรรมการนี้มีหน้าที่

ก) สืบค้น คัดเลือกและรวบรวมหลักกฎหมายอิสลามจากแหล่งที่มาทุก ๆ แห่งเท่าที่จะหาได้

ข) การยกร่างประมวลกฎหมายอิสลามโดยการคัดเลือกและผสมผสานกันระหว่างกฎหมายฟิลิปปินส์และกฎหมายอิสลาม

ค) เตรียมการยกร่างเบื้องต้นเพื่อโครงการประมวลกฎหมายมุสลิมฟิลิปปินส์ซึ่งประกอบด้วยกฎหมายอิสลาม (Shariah) หลักนิติศาสตร์อิสลาม (Fiqh) และกฎหมายประเพณี (Adat) เป็นต้น

คณะกรรมการดังกล่าว ได้ร่างประมวลกฎหมายการบริหารกฎหมายอิสลามขึ้น (Code on the Administration of muslim laws)

ในระยะที่ 2 ได้ก่อตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาประมวลกฎหมายมุสลิมฟิลิปปินส์ (The Presidential Commission to review Code of Philippines muslim law) ตาม Executive Order no. 442 โดยคณะกรรมการประกอบไปด้วย

- | | |
|---|---------------|
| 1. คณะบดีสถาบันศึกษาอิสลาม | เป็นประธาน |
| 2. ผู้แทนศาลสูง | เป็นรองประธาน |
| 3. ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม | เป็นกรรมการ |
| 4. ผู้แทนสมาคมทนายความแห่งฟิลิปปินส์ | " |
| 5. ผู้แทนศูนย์กฎหมายมหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ | " |
| 6. ผู้แทนเถรสภาแคทอลิกแห่งฟิลิปปินส์ | " |
| 7. นักกฎหมายอิสลามที่มีชื่อเสียง 2 นาย | " |
| 8. ผู้นำศาสนาอิสลามที่มีชื่อเสียง 2 นาย | " |
| 9. หัวหน้าโครงการ ของคณะกรรมการเพื่อการประมวลกฎหมายมุสลิม | " |

คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่พิจารณาตรวจสอบว่า ประมวลกฎหมายบริหารกฎหมายอิสลาม ที่ได้เสนอโดยคณะทำงานเพื่อการประมวลกฎหมาย (The Research Staff for the codification of Philippines muslim law) อิสลามฟิลิปปินส์¹ โดยได้วางแนวทางเป็นพื้นฐานในการทำงาน ดังนี้²

1. แม้ว่าระบบกฎหมายอิสลามจะประกอบด้วยกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา รัฐคำสัตรีกฎหมายระหว่างประเทศและหลักคำสอน แต่หลักการที่จะนำเอามาประมวลนั้นจะต้อง เป็นหลักที่เป็นพื้นฐานทางสถานภาพของบุคคล
2. กฎหมายสถานภาพบุคคลจะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติภายใต้หลักกฎหมายอิสลามทั้งหมด และที่เป็นข้อห้ามตามกฎหมายอิสลามก็ยังคง เป็นข้อห้ามอยู่เช่นเดิม
3. บทบัญญัติที่มีเนื้อหายังเป็นปัญหาที่ยากจะจำแนกออกได้ จะต้องยึดถือตามหลักการพื้นฐานของรัฐและรายละเอียดจากผู้พิพากษาเท่านั้น
4. คำสอนต่าง ๆ ที่จะนำมาประมวลนั้น จะต้องไม่ขัดแย้งกับหลักการตามรัฐธรรมนูญฟิลิปปินส์ และ
5. คำสอนนั้นจะต้องเป็นไปตามคำอธิบายของ 4 สำนักกฎหมาย³

¹Executive order No. 442 Creating the Presidential commission to review the code of Philippine muslim laws.

²จากรายงานของคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบประมวลกฎหมายมุสลิมฟิลิปปินส์ เมื่อ 29 สิงหาคม 1975.

³4 สำนักกฎหมาย คือ 1. สำนักกฎหมายฮานาฟี 2. สำนักกฎหมายมาลิกี 3. สำนักกฎหมายชาฟีอี 4. สำนักกฎหมายฮัมบาลีย์.

แต่อย่างไรก็ตาม สำนักกฎหมายที่ใช้อยู่ในฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่ คือ สำนักกฎหมายชาฟีอี สำนักกฎหมายอื่นจึงไม่ได้รับการพิจารณาจากร่างประมวลกฎหมาย

ข. สถานการณ์กฎหมายอิสลามในประเทศไทย

ประเทศไทยแม้จะไม่ได้ตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกเหมือนชาติอื่น ๆ ในเอเชียก็ตาม แต่ประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบจากลัทธิล่าอาณานิคมไม่ยิ่งหย่อนกว่าชาติอื่น ๆ ซึ่งเป็นเหตุให้ประเทศต้องปรับปรุงรูปแบบในการปกครองประเทศให้ทันสมัยและให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่อการคุกคามของลัทธิล่าอาณานิคม สิ่งส่งผลกระทบต่อกฎหมายอิสลามที่เคยใช้อยู่ในบริเวณจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีชายแดนติดกับประเทศมาเลเซียซึ่งได้ตกเป็นอาณานิคมของอังกฤษ ดังนั้น การใช้กฎหมายอิสลามจึงขึ้นกับนโยบายและรูปแบบของการปกครองของรัฐที่มีต่อบริเวณที่เรียกว่า จังหวัดชายแดนภาคใต้ สถานภาพของกฎหมายอิสลามจึงอาจแบ่งออกเป็น 3 ยุค คือ

1. สถานการณ์ของกฎหมายอิสลามในยุคสุโขทัย อโยธยาและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น

ในยุคนี้นโยบายด้านการปกครองต่อบริเวณที่เรียกว่า จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นรูปแบบหัวเมืองประเทศราช คือ ไทยได้หัวเมืองเหล่านั้นมาในลักษณะที่เป็นเมืองขึ้น ใช้หลักการปกครองโดยไม่ได้ส่งคนไปปกครอง แต่ให้ปกครองกันเองเพียงแต่ต้องแสดงความสวามิภักดิ์ต่อไทยทุกปี¹ แต่ละหัวเมืองจะทำการปกครองตนเอง และบริหารกิจการทั้งหลายด้วยความเป็นอิสระเด็ดขาดจากการปกครองของไทย² การปกครองแต่ละหัวเมือง เจ้าเมืองมีอำนาจในการปกครองตามขนบธรรมเนียม³ ซึ่งก็หมายถึงเป็นการปกครองเมืองตามหลักการของคำสอนอิสลามนั่นเอง เพราะเจ้าเมืองและประชาชนเกือบทั้งหมดนับถือคำสอนอิสลาม การตัดสินใจที่ความกึ่งอยู่ในอำนาจของเจ้าเมือง ก็ต้องเป็นไปตามหลักกฎหมายอิสลามที่ใช้อยู่ในหัวเมืองเหล่านั้น กฎหมายอิสลามในขณะนั้นจึงมีฐานะเป็นตัวกำหนดความสัมพันธ์ของประชากรในหัวเมืองเหล่านั้น

¹ ลีชิต ธีรเวคิน, ชนกลุ่มน้อยในประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร: แพรวพินทยา 2521), หน้า 224 (อ้างอิงจากเอกสารกองประสานราชการ กรมการปกครอง, เรื่องเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้, โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น, กรมการปกครอง 2521, หน้า 2)

² เรื่องเดียวกัน.

³ วุฒิชัย มุลศิลป์ กับ สัมโชติ อ่องสกุล (บรรณาธิการ), มรดกแห่งกบฏ : วิเคราะห์เปรียบเทียบเอกสารทางวิชาการของลัทธิคอมมิวนิสต์และเคราะห์แห่งประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แสงรุ่งการพิมพ์ 2524), หน้า 363.

โดยที่รัฐบาลกลางไม่ได้นำเอาหลักกฎหมายแพ่งที่ใช้ยู่ทั่ว ๆ ไปมาบังคับใช้ในหัวเมืองเหล่านี้
อย่างไรก็ตามภายหลังเหตุการณ์ก่อความวุ่นวาย ในปี พ.ศ. 2374-2375 ในสมัยพระบาท
สมเด็จพระนั่งเกล้า ได้ดำเนินการควบคุมการปกครองหัว เมืองปัตตานีและไทรบุรีให้รัดกุมยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะกฎหมายการตัดสินคดีความ ดังปรากฏในพงศาวดารเมืองปัตตานี ว่า " ...คดี
ถ้อยความที่ปรับไหมหรือตัดสินก็ใช้ตามพระราชกำหนดกฎหมายสยามทั้งสิ้น"¹ ซึ่งนับว่ารัฐบาล
ได้เข้ามาทำการปรับปรุงการใช้กฎหมายในหัวเมืองเหล่านี้ ส่วนการใช้กฎหมายอิสลามก็ยังคง
มีอยู่ แม้ต่อมาจะได้มีการปรับปรุงแนวทางการปกครองหัว เมืองเหล่านี้ใหม่ รัฐบาลก็ยังคงให้
ใช้กฎหมายอิสลามอยู่เช่นเดิม ซึ่งต่อมาได้กลายมาเป็นรากฐานที่สำคัญของการใช้กฎหมาย
อิสลามในประเทศไทย

2. สถานการณ์ของกฎหมายอิสลามในยุคปฏิรูปการปกครองในรัชกาลที่ 5 เนื่องจาก
สถานการณ์การปกครองในสมัยนั้นยังคงล้าสมัยไม่เหมาะสมกับสภาวะการณที่เปลี่ยนแปลงไป
และจากการคุกคามของมหาอำนาจตะวันตกในยุคล่าอาณานิคม ทำให้ต้องมีการปฏิรูปการปกครอง
ในรัชกาลที่ 5 ผลจากการปฏิรูปการปกครอง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อกฎหมายอิสลามที่ใช้ยู่ใน
บริเวณจังหวัดภาคใต้ในขณะนั้น ดังนี้

ก) การใช้กฎหมายอิสลามในระยะแรก การดำเนินการในระยะนี้รัฐมี
นโยบายเกี่ยวกับการใช้กฎหมายอิสลามโดยการตัดสินคดีความยังคงให้เจ้าเมืองมีอำนาจใน
การตัดสินคดีต่าง ๆ ตามกฎหมายประเพณีอิสลาม เว้นแต่คดีที่มีโทษถึงประหารชีวิตหรือรับทรัพย์
เจ้าเมืองต้องขอพระบรมราชานุญาตเหมือนหัวเมืองชั้นในเสียก่อน และคดีที่มีการอุทธรณ์ต้องส่ง
ให้ข้าหลวงพิจารณา²

¹ วุฒิชัย มุลสิลี กับ สัมโชติ อ่องสกุล. (บรรณาธิการ), มลลเทศาภิบาล
วิเคราะห์เปรียบเทียบเอกสารทางวิชาการของสมาคมสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, อ่างแล้ง,
หน้า 354 (อ้างจากพระยาวิเชียรคีรี, พงศาวดารเมืองปัตตานี, ประชุมพงศาวดารฉบับ
หอสมุดแห่งชาติ เล่ม 2 ก้าวหน้า 2507 หน้า 22).

² เรื่องเดียวกัน, หน้า 363.

จากแนวนโยบายดังกล่าว แสดงให้เห็นว่ารัฐได้ให้ความสำคัญในการนำเอากฎหมายอิสลามมาบังคับใช้ในชุมชนมุสลิม เพื่อเป็นการประสานหลักการปกครองแบบใหม่ให้เข้ากับธรรมเนียมเดิมของท้องถิ่นอย่างระมัดระวังโดยมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือขนบธรรมเนียมแบบแผนในหัวเมืองเหล่านี้้อย่างค่อยเป็นค่อยไป¹ อย่างไรก็ตาม รัฐก็ได้พยายามจะเข้ามาจัดระเบียบการใช้กฎหมายอิสลามให้มีระเบียบแบบแผนและยุติธรรมมากขึ้น² โดยให้มีคณะผู้พิพากษาทำการพิจารณาตัดสินคดีตามกระบวนการยุติธรรมสมัยใหม่ แต่คดีที่เกี่ยวกับสิทธิคำสอนอิสลามให้พิจารณาตามหลักกฎหมายอิสลาม³ โดยไม่ได้ทำการยกเลิกศาลโตะกาลี แต่ได้มีการแก้ไขด้วยการเลือกอาจารย์คำสอนอิสลามที่มีคนนับถือมาก เป็นตะโตะยุติธรรมขึ้นไว้คณะหนึ่งราว 20 คน ถ้าคนนับถือคำสอนอิสลามเป็นความกัน หรือเป็นจำเลยในคดีที่ต้องตัดสินด้วยกฎหมายทางคำสอน คือ ความผิดเมีย ความมรดก ให้คู่ความเลือกตะโตะยุติธรรมที่ตั้งไว้เป็นอนุญาโตตุลาการฝ่ายละคนหรือหลายคนตามตกลง มานั่งชำระและตัดสินคดีความในศาลทั่วไป แต่ถ้าคู่ความเป็นไทยพุทธหรือคดีประเภทอื่น ศาลทั่วไปจะเป็นผู้ชำระและตัดสินคดีตามกฎหมายบ้านเมือง⁴

ข) การใช้กฎหมายอิสลามในระยะที่ 2 เมื่อการเข้าไปจัดการบริเวณ 7 หัวเมืองในตอนแรกไม่ประสบความสำเร็จตามความมุ่งหมาย รัฐบาลกลางจึงเปลี่ยนวิธีการ

¹ วุฒิชัย มุลศิลป์ กับ สัมโชติ อ่องสกุล (บรรณาธิการ), มณฑลเทศาภิบาล วิเคราะห์เปรียบเทียบเอกสารทางวิชาการของสมาคมสังคมสังเคราะห์แห่งประเทศไทย, อังแล้ว หน้า 364.

² เรื่องเดียวกัน, หน้า 366 (อ้างจากสมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพ ประวัติพระยายมราช (ปั้น สุขุม) ในประวัติเจ้าพระยามหาเสนา เจ้าพระยาบดินทรเดชา เจ้าพระยายมราช, คุรุสภา 2518 หน้า 108-109).

³ เรื่องเดียวกัน, หน้า 343.

⁴ พิพัฒน์ จักรางกูร, "กฎหมายอิสลาม", การสัมมนาการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลาและสตูล, กระทรวงยุติธรรม, 2525, หน้า 307 (คัดจากบทบัญญัติ เล่ม 28 ตอน 1 พ.ศ. 2514).

จัดการใหม่โดยใช้อำนาจบังคับใช้สำหรับปกครองบริเวณ 7 หัวเมือง ร.ศ. 120 เพื่อกำหนดนโยบายให้แน่ชัดลงไป และเพื่อให้เจ้าเมืองอิสลามทั้งหลายได้รู้ว่า รัฐบาลจะเข้าไปดำเนินการให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบริเวณ 7 หัวเมืองมากน้อยเพียงไร

ผลจากการประกาศใช้กฎข้อบังคับสำหรับปกครองบริเวณ 7 หัวเมือง ก่อให้เกิดผลต่อการใช้กฎหมายอิสลาม คือ

1) กฎข้อบังคับสำหรับปกครองบริเวณ 7 หัวเมือง ร.ศ. 120 ว่าด้วยการศาลโดยได้กำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับกิจการศาลในบริเวณ 7 หัวเมือง ดังนี้

ว่าด้วยการโรงศาล

ข้อ 30 ให้ใช้พระธรรมนูญศาลหัวเมืองรัตนโกสินทร์ คก 114 ในบริเวณนี้ เว้นคำว่า "ศาลมณฑล" ให้เข้าใจว่า "ศาลบริเวณ" แลคำว่า "ข้าหลวงเทศาภิบาล" ให้ใช้คำว่า "ข้าหลวงใหญ่ประจำบริเวณ" แลการที่ตั้ง หรือจะเลื่อน หรือจะเปลี่ยนผู้พิพากษาในบริเวณ 7 หัวเมืองตามความที่ไว้ในมาตรา 10 ของพระธรรมนูญหัวเมือง ร.ศ. 114 นั้น ให้ถือว่าเป็นหน้าที่ของเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย จะนำความกราบบังคมทูล และให้ข้าหลวงใหญ่ประจำบริเวณมีใบบอกในการที่เกี่ยวข้องแก่อั้ง หรือเลื่อน หรือเปลี่ยนผู้พิพากษาในบริเวณมายังเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย

ข้อ 31 ให้มีศาลเป็น 3 ชั้น คือ

1. ศาลบริเวณ
2. ศาลเมือง
3. ศาลแขวง

และให้ผู้พิพากษาสำหรับศาลเหล่านี้เพื่อพิจารณาพิพากษาคดีตามพระราชกำหนดกฎหมาย

ข้อ 32 ให้ใช้พระราชกำหนดกฎหมายทั้งปวง ในความอาญาแลความแพ่ง แต่ความแพ่งซึ่งเกี่ยวข้องกับศาสนาอิสลามเรื่องผิวเมียกิติ แลเรื่องมรดกก็ดี ซึ่งคนนับถือศาสนาอิสลามเป็นทั้งโจทก์ จำเลย หรือเป็นจำเลย ให้ใช้กฎหมายอิสลามในการพิจารณาแลพิพากษา แลให้โต๊ะกาฎีซึ่งเป็นรู้แลเป็นที่นับถือศาสนาอิสลาม เป็นผู้พิพากษาตามกฎหมายอิสลามนั้น¹

¹ คัดเฉพาะแต่ข้อความที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายอิสลามลักษณะครอบครัวมรดก

ข้อบังคับสำหรับปกครองบริเวณ 7 หัวเมือง ร.ศ. 120 ได้ประกาศใช้ในวันที่ 10 ธันวาคม ร.ศ. 120 หรือ พ.ศ. 2444 ซึ่งนับว่าเป็นกฎหมายของรัฐบาลแรกที่ได้ออกมา กำหนดรูปแบบการใช้กฎหมายอิสลามเอาไว้อย่างชัดเจน คือ นอกจากจะได้ก่อตั้งศาลขึ้นเพื่อพิจารณาคดีตามตัวบทกฎหมายทั่ว ๆ ไปโดยอยู่ภายใต้การดูแลของเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย และยังได้กำหนดให้ใช้กฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่งมาบังคับใช้บริเวณ 7 หัวเมืองเหมือนส่วนอื่น ๆ ของประเทศ เว้นแต่คดีแพ่งที่เกี่ยวข้องด้วยครอบครัวมรดก ซึ่งผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามเป็นทั้งโจทก์จำเลย หรือเป็นจำเลย สิ่งเป็นการกำหนดขอบเขตการใช้กฎหมายอิสลามเฉพาะในเรื่องครอบครัวมรดก และคู่ความนับถือศาสนาอิสลามเป็นทั้งโจทก์และจำเลย โดยมีโต๊ะกาฎีซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในกฎหมายอิสลามเป็นผู้ตัดสิน ซึ่งเดิมก่อนประกาศใช้กฎข้อบังคับสำหรับปกครองบริเวณ 7 หัวเมือง ร.ศ. 120 นั้น การใช้กฎหมายอิสลามยังไม่มีขอบเขตที่แน่นอน เป็นเพียงแต่รัฐได้ยอมให้เจ้าเมืองนำเอากฎหมายอิสลามมาพิจารณาคดีที่เกี่ยวกับสิทธิศาสนาอิสลาม

การประกาศใช้กฎข้อบังคับสำหรับปกครองบริเวณเจ็ดหัวเมืองที่เกี่ยวกับการโรงศาล แสดงให้เห็นนโยบายของรัฐในยุคนั้นที่จะให้มีการนำเอากฎหมายอิสลามมาบังคับใช้แก่ประชาชนพลเมืองที่นับถือศาสนาอิสลามในบริเวณเจ็ดหัวเมือง เพื่อที่จะให้ประชาชนเหล่านี้ได้บำเพ็ญสิทธิศาสนาโดยเลื่อมใส

2) สารตราของกระทรวงยุติธรรมที่ 30 /4353 จังหวัดสุลต ซึ่งไม่ได้อยู่ในบริเวณเจ็ดหัวเมืองจึงไม่อาจนำเอากฎข้อบังคับสำหรับปกครองบริเวณเจ็ดหัวเมืองว่าด้วยการโรงศาลมาบังคับใช้ ในด้านเกี่ยวกับการศาล สุลตก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีชาวอิสลามเป็นจำนวนมาก เดิมสุลตเคยมีศาลเกี่ยวกับศาสนา แต่ถูกยุบไป อิสลามศาสนิกจึงไม่ยอมขึ้นศาลในคดีที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวมรดกโดยอ้างว่า แม้ศาลไทยจะพิจารณาคดีไปแล้วก็ตามทางศาสนาของเขาไม่ถือว่าเป็นคำวินิจฉัยที่สมบูรณ์ ด้วยเหตุดังกล่าว พระยาสมันตรัฐบุรินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุลต จึงเสนอความเห็นไปยังสมุหเทศาภิบาล สำเร็จราชการมณฑลภูเก็ต ซึ่งสมัยนั้นสุลตขึ้นอยู่กับมณฑลภูเก็ต¹ ขอให้มีการศาลทางศาสนา เช่นเดียวกับกฎข้อบังคับ สำหรับ

¹ จังหวัดสุลต ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สุลตขึ้นกับมณฑลไทรบุรี ครั้นต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2452 ไทยทำหนังสือสัญญากับอังกฤษ ยอมสละอำนาจอปกครอง



ปกครองบริเวณเจ็ดหัวเมือง¹

ต่อมาในปี พ.ศ. 2460 ได้มีสารตราที่ 30/4353² ลงวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2460 ร่องเล่านาบดีกระทรวงยุติธรรมดำเนินการตามกระแสพระบรมราชโองการ—

เหนือมณฑล มลายู คือไทรบุรี กลันตัน ตรังกานุและปะลิสให้แก่อังกฤษ คงเหลือสตูลเพียงเมืองเดียวที่ยังอยู่ในราชอาณาจักรไทย จึงโปรดเกล้าฯ ให้สตูลรวมอยู่ในมณฑลภูเก็ต เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2452 และต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ผนวกหลวงและทางรถไฟติดต่อไปมากับจังหวัดสงขลาได้สะดวกกว่าที่จะไปมากับจังหวัดภูเก็ต จึงโปรดเกล้าฯ ให้สตูลรวมอยู่ในมณฑลนครศรีธรรมราช ซึ่งตั้งที่ทำการอยู่ที่จังหวัดสงขลา เมื่อปี พ.ศ. 2468

¹พิพัฒน์ สักการกฎ, กฎหมายอิสลาม, อ่างแล้ว, หน้า 308.

²สารตรามหาอำมาตย์เอก เจ้าพระยาอภัยราชรมหายุติธรรม เล่านาบดีกระทรวงยุติธรรม ถึงนายพลโทพระยาลูรินทรราชา ลมูหเทศาภิบาลสำเร็จราชการมณฑลภูเก็ต

ด้วยมีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ สั่งว่า จังหวัดสตูลมีราษฎรพลเมืองเป็นผู้ถือศรัทธาศาสนาอิสลามอาศัยอยู่เป็นอันมาก มีพระราชประสงค์จะหาทุนบำรุงให้ได้บำเพ็ญศรัทธาศาสนานั้นโดยเลื่อมอาภรณ์ได้สำเร็จดังนี้ เป็นพระราชกรณีจำนงสืบมาแต่โบราณมหากษัตริย์จึงได้มีพระราชบัญญัติไว้ว่า ถ้าบุคคลผู้ถือศรัทธาศาสนาอิสลามพิพาทกันด้วยความแพ่งลักษณะผิวเผินและทรัพย์สินรกรกให้ตุลาการพิจารณาคดีและบังคับคดีโดยสิทธิประเพณีอิสลามตามคัมภีร์โกหร่านพระมหะหมัดนั้น ดังปรากฏในกระทรวง หลวงกักตติวิจารย์ตุลาการ กรมท่าขวา ขึ้นแต่จุฬาราชมนตรีนั้นสืบมา และมุสลิมเป็นกระบวนพิจารณาความแพ่งได้โปรดเกล้าฯ ให้ขยายออกมาบังคับใช้ทั่วพระราชอาณาเขตคาบสมุทรมลายูบักันได้ ซึ่งมีราษฎรพลเมืองนับถือศรัทธาอิสลามอยู่หนาแน่น ให้ตั้งตำแหน่งโต๊ะกาซีเป็นผู้บังคับคดีตามประเพณีนิยมนั้น พระราชบัญญัตินี้ให้คงรักษาไว้มิให้เพิกถอน ควรแต่จะผ่อนผันวางวิธีเลือกสรรตั้งตำแหน่งกาซีให้ลงเป็นระเบียบ ดังนี้ คือ

ข้อ 1 โต๊ะกาซีผู้บรรพโทโกหร่านควรได้สมมตินิยมของราษฎรอ่าวอิสลามในแขวงนั้น เป็นกอบปรด้วยวิญญูควรแก่เคารพนับถือในฐานะผู้ใหญ่ เป็นผู้กอบปรด้วยคุณวุฒิสามารถในคัมภีร์

ให้ขยายการใช้กฎหมายอิสลามไปถึงจังหวัดสุล

นับแต่นั้นมาการใช้กฎหมายอิสลามในจังหวัดสุลก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสารตราที่ 30/4353 ของกระทรวงยุติธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขยายการบังคับใช้กฎหมายอิสลามออกไปทั่วพระราชอาณาเขตคาบสมุทรมาลายูซึ่งมีประชาชนนับถือศาสนาอิสลามอย่างหนาแน่น เพื่อจะได้ให้มุสลิมบำเพ็ญสิทธิศาสนาโดยเสมอกัน ซึ่งเป็นพระราชประสงค์ของพระมหากษัตริย์ไทยสืบมาแต่โบราณ

สารตราฉบับนี้ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการใช้กฎหมายอิสลามเอาไว้ ดังนี้

1. ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งตะต๊ะยุติธรรมเอาไว้ โดยกำหนดคุณสมบัติเอาไว้ว่า ต้องเป็นผู้ที่ประชาชนอิสลามนับถือ เป็นผู้ก่อปรด้วยวิญญูธรรมแก่การเคารพ

โกหร่านโดยสมควร เป็นผู้มีความรักต่อฝ่าละล่องธุลีพระบาท และสมัครรักดีต่อราชการของพระเจ้าอยู่หัวดังนี้เป็นลักษณะสำคัญข้อที่พระยาลมุนเทศาภิบาลมีใบบอกเข้าไปว่า ได้ปรึกษาหารือพร้อมด้วยผู้ราชการจังหวัดเห็นว่า หะยีเต็น 1 หะยีฮัน 1 กอปรด้วยคุณวุฒิสามารถเป็นที่ประชาชนพลเมืองนิยมนับถืออยู่เป็นอันมากเห็นปานดังนั้น สมควรที่จะเลือกสรรเอาขึ้นตั้งไว้ในหน้าที่ตุลาการฝ่ายอิสลามได้นั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตแล้ว

ข้อ 2 แต่ที่สืบไปให้เรียกตำแหน่งตุลาการนี้ว่า ตะต๊ะยุติธรรม เทียบค่าเล่าเรียนยุติธรรมในมณฑลพายัพหน้าที่เฉพาะเป็นกาที่ผู้ปรับบทโกหร่าน เป็นตุลาการบังคับแพ่งประเพณีอิสลามเทียบอำนาจศาลแขวงในพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 25 อยู่ในบังคับบัญชาของศาลมณฑลฎ กิตได้ครอบงำทั่วไป

ข้อ 3 อำนาจตะต๊ะยุติธรรมนี้ได้ฟังจำกัดว่า บังคับได้แต่คดีบุคคลผู้ถือศาสนาอิสลามพิพาทกันด้วยความแพ่งลักษณะฉ้อฉลและทรัพย์มรดก อันจะฟังยกบทโกหร่านขึ้นปรับได้โดยชอบด้วยขบวนการพิจารณานอกจากที่จะว่ากล่าวเปรียบเทียบกับคดีนั้น ๆ ให้ตะต๊ะยุติธรรมทำคำตัดสินลงข้อแต่ 2 นาย หรือพร้อมด้วยผู้พิพากษาศาลจังหวัดรวมเป็น 2 นาย สิ่งบังคับเป็นคำพิพากษาคดีแห่งประเพณีอิสลามได้ และคู่ความพึงอุทธรณ์ฎีกาได้เป็นลำดับตามพระราชกำหนดกฎหมายให้พระยาลมุนทรราชากับพระพิพิธคำสตรราชล่ลาบติราชการตามกระแสพระบรมราชโองการนี้

นับถือในฐานะผู้ใหญ่มีความรอบรู้ในหลักกฎหมายอิสลามและมีความจงรักภักดีต่อแผ่นดิน เป็น
ตุลาการพิจารณาคดีแพ่ง ประเพณีอิสลาม

2. การใช้กฎหมายอิสลามมีเขตอำนาจพิจารณาคดีเฉพาะคดีแพ่งลักษณะผิว เมียและ
มรดกโดยตะต๊ะยุติธรรมที่ตัดสินนั้นต้องลงชื่อในคำพิพากษา 2 คน หรือพร้อมกับผู้พิพากษาคำล
จังหวัดรวมเป็น 2 คน

3. คดีที่จะต้องบังคับตามหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวมรดกนั้น คู่ความจะ
ต้องนับถือศาสนาอิสลาม

4. การอุทธรณ์ฎีกา สามารถทำได้ตามกฎหมาย

นับว่าสารตราฉบับนี้เป็นการเพิ่มเติมการใช้กฎหมายอิสลามตามบทบัญญัติของกฎข้อ
บังคับบริเวณเจ็ดหัวเมือง ร.ศ. 120 กล่าว คือ

1. ได้ขยายการใช้กฎหมายอิสลามให้ครอบคลุมไปถึงจังหวัดสตูล ซึ่งเดิมตามกฎหมาย
ข้อบังคับสำหรับปกครองบริเวณเจ็ดหัวเมืองนั้น ใช้เฉพาะจังหวัดปัตตานี นราธิวาส และยะลา
ซึ่งนับว่าได้ก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคแก่ผู้ทักับถือศาสนาอิสลามซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด
ใกล้เคียงกับบริเวณเจ็ดหัวเมืองเป็นอย่างมาก เช่น ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน
จังหวัดสตูลไม่สามารถร้องขอให้ศาลตามกฎหมายอิสลามใช้พิพากษาคดีผิว เมียและมรดกได้

2. ได้กำหนดให้คดีแพ่งลักษณะผิว เมียและมรดกที่จะพิจารณาตามหลักกฎหมาย
อิสลามนั้น คู่ความจะต้องนับถือศาสนาอิสลามซึ่ง เดิมตามกฎหมายข้อบังคับสำหรับปกครองบริเวณเจ็ด
หัวเมืองนั้นเพียงแต่คู่ความที่เป็นจำเลยนับถือศาสนาอิสลามก็สามารถบังคับตามหลักกฎหมาย
อิสลามได้ ซึ่งก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ผู้ทักับถือศาสนาอื่นแต่มาสมรสกับผู้ทักับถือศาสนา
อิสลามหรือเกี่ยวพันทางครอบครัวมรดกกับผู้ทักับถือศาสนาอิสลาม

3. ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะดำรงตำแหน่งตะต๊ะยุติธรรมเพิ่มขึ้น ซึ่งเกิดตาม
กฎข้อบังคับสำหรับปกครองบริเวณ 7 หัวเมืองได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่ง
ตะต๊ะยุติธรรมเพียงแต่เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามและรู้กฎหมายอิสลามก็พอแล้วซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าทางราชการสมัยนั้นไม่ได้เพ่งเล็งถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งตะต๊ะยุติธรรม¹

¹วิศิษฐ์ ลิขานนท์, "ตะต๊ะยุติธรรม" การสมมนาการใช้กฎหมายอิสลามในเขต
จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาสและสตูล, กระทรวงยุติธรรม 2525, หน้า 353.

3) การกำหนดอายุความมรดก ระหว่างคนถือคำสอนอิสลามตามหลัก
กฎหมายอิสลามไม่มีบัญญัติถึงอายุความมรดกในระหว่างใช้กฎข้อบังคับสำหรับปกครองบริเวณ
7 หัวเมือง ร.ศ. 120 นั้นจึงได้ประสบความยุ่งยากในเรื่องกำหนดอายุความเพราะตาม
ประเพณีของแต่ละเมืองนั้นอายุความมากบ้างน้อยบ้างไม่เท่ากันเป็นการยุ่งยากแก่คู่ความและ
ตะโตะยุติธรรมในการพิจารณาคดี จึงได้ประกาศของเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยโดยกำหนด
อายุความสำหรับมรดกระหว่างมุสลิมเอาไว้ 1 ปีนับแต่วันเจ้ามรดกถึงแก่ความตายถ้าพ้นกำหนด
1 ปีห้ามมิให้ศาลรับไว้พิจารณา¹ ฉะนั้นคดีมรดกที่ฟ้องร้องต่อศาลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2448 ต้องถืออายุความมรดก 1 ปี

4) อำนาจและวิธีที่ตะโตะยุติธรรมพิจารณาคดีครอบครัวมรดก ในศาล
มณฑลปัตตานี วิธีการจัดการคดีที่เกี่ยวข้องด้วยคำสอนอิสลามในศาลมณฑลปัตตานี คือ

¹ ประกาศกำหนดอายุความมรดกในระหว่างคนถือคำสอนอิสลาม

พระเจ้าน้องยาเธอกรมหลวงดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย รับ
พระราชโองการใส่เกล้าฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ประกาศทราบทั่วกันว่า

1. ด้วยความมรดกในระหว่างคนถือคำสอนอิสลาม ซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ตะโตะกาสิ เป็นอนุญาตโตตุลาการชำระอยู่ตามคำสอนอิสลามนั้น กำหนดอายุความว่าเท่าใด
ปีจึงจะฟ้องร้องกันได้และเท่าใดปีจึงจะพ้นกำหนด ข้อนี้ตามประเพณีที่เป็นอยู่บาง เมืองก็มีมาก
ปี บางเมืองก็น้อยปี ไม่เสมอกันเป็นการยากแก่ผู้มคิตและตะโตะกาสิที่เป็นตุลาการอยู่

2. ข้าหลวงใหญ่ประจำบริเวณจึงได้ประชุมตะโตะกาสิและตะอิหม่ารวม 41 นาย
ณ ที่ศาลบริเวณเมืองตานีเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ค.ศ. 122 ตกลงเห็นชอบพร้อมกันว่าควรกำหนด
อายุความมรดกไว้เพียง 1 ปีถ้วน

3. เพราะฉะนั้นบรรดาความมรดกที่จะว่ากล่าวกันในเวลานี้ ให้ว่ากล่าวกันตาม
กำหนดอายุความตามประเพณีบ้านเมืองซึ่งมีมาแต่เดิม แต่ความมรดกที่จะฟ้องร้องต่อศาลตั้งแต
วันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 124 ต่อไป ให้ศาลถือกำหนดอายุความว่ากล่าวกันได้แต่ภายในกำหนด
1 ปี นับแต่วันผู้ตายได้ตายไป ถ้าพ้นกำหนด 1 ปี ห้ามมิให้ศาลรับไว้พิจารณา

1. ต้องเป็นคดีที่เกี่ยวข้องครอบครัวมรดก
2. โจทก์ จำเลย ทั้งสองฝ่ายหรือแต่จำเลยฝ่ายเดียวเป็นผู้ขับฟ้องศาลอิสลาม
3. การยื่นฟ้องคดี โดยปกติแล้วคดีความทุกอย่างจะต้องดำเนินการฟ้องร้องที่ศาล

บ้านเมืองแต่ถ้าเป็นคดีที่เกี่ยวข้องศาลอิสลาม เมื่อศาลรับฟ้องแล้วส่งคำฟ้องให้แก่จำเลย เมื่อจำเลยยื่นคำให้การ ศาลมีความเห็นว่า เป็นคดีเกี่ยวกับครอบครัวมรดกซึ่งจะต้องพิจารณา ศาลอิสลามแล้ว ศาลจึงบังคับให้โจทก์ จำเลย เลือกตะโตะยุติธรรมที่ข้าหลวงเทศาภิบาล ได้ประชุมเลือกตั้งไว้สำหรับเมืองเป็นอนุญาโตตุลาการพิจารณาคดี อนุญาโตตุลาการต้องทำการพิจารณาคดีในศาลบ้านเมืองโดยโจทก์ จำเลย จะเลือกตะโตะยุติธรรมต่างกันหรือคนเดียวก็ได้ และศาลต้องส่งสำนวนเรื่องนั้นไปให้ตะโตะยุติธรรม ตะโตะยุติธรรมที่ถูกเลือกจึงมีอำนาจพิจารณาคดีเรื่องนั้น เมื่อพิจารณาตัดสินเสร็จแล้วต้องส่งสำนวนคืนมายังศาลบ้านเมืองก็เป็นหมดหน้าที่ของตะโตะยุติธรรม ส่วนผู้พิพากษาเมื่อได้รับสำนวนความจากตะโตะยุติธรรมแล้ว ผู้พิพากษาต้องบังคับคดีนั้นตลอดไปไม่เกี่ยวกับตะโตะยุติธรรม¹

จะเห็นว่าการพิจารณาคดีในคดีครอบครัวมรดกโดยตะโตะยุติธรรมนั้นต้องกระทำในนามของศาลบ้านเมือง

5) ตะโตะยุติธรรม ตะโตะยุติธรรมหรือในภาษามลายู เรียกว่า

โตะ-กอฎี หมายถึงผู้ชี้ขาดหรือตัดสินคดีซึ่งหมายถึงผู้พิพากษา ตะโตะยุติธรรมมีในประเทศไทย ครั้งแรกเมื่อ ร.ศ. 120 ซึ่งเรียกว่าโตะกาฎีตามกฎหมายข้อบังคับสำหรับปกครองบริเวณเจ็ดหัวเมือง ซึ่งตราขึ้นเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2444 ตะโตะยุติธรรมมีหน้าที่พิจารณาคดีแพ่งเกี่ยวกับ ครอบครัวมรดกตามกฎหมายข้อบังคับบริเวณเจ็ดหัวเมือง ข้อ 32 นอกจากนี้ตะโตะยังมีหน้าที่ร่วมมือกับฝ่ายบ้านเมืองเป็นกรรมการสอบสวนความรู้ทางภาษมลายูของข้าราชการในสังกัดนั้น ๆ ด้วย ตามกฎหมายข้อบังคับสำหรับปกครองบริเวณเจ็ดหัวเมือง ข้อ 28²

¹ ณรงค์ ศิริปะชะนะ, แนวกฎหมายอิสลาม ลักษณะมรดก, (นครศรีธรรมราช: โรงพิมพ์ ศรีอักษร) 2518, หน้า 110-111 (คัดจากหนังสือเทศาภิบาล ร.ศ. 126 เล่ม 3 หน้า 14)

² กฎข้อบังคับสำหรับปกครองบริเวณเจ็ดหัวเมือง ข้อ 28 ดังนี้

ถ้าข้าหลวงเทศาภิบาลได้พร้อมด้วยพระยาเมืองและโตะกาฎีเมืองใดได้สอบแล้ว เห็นว่าข้าราชการคนใดพูดภาษามลายูได้ให้พร้อมกันเซ็นชื่อออกประกาศนียบัตรให้ข้าราชการผู้นั้น และข้าหลวงเทศาภิบาลมีอำนาจให้เงินหลวงเป็นรางวัลไม่เกิน 100 บาท

คุณสมบัติของตะไต้ะยุติธรรมตามกฎหมายฉบับสำหรับปกครองบริเวณเจ็ดหัวเมืองนั้น ได้กำหนดคุณสมบัติของตะไต้ะยุติธรรมเอาไว้เพียงว่า เป็นผู้และผู้นับถือศาสนาอิสลามตามกฎหมายฉบับสำหรับปกครองบริเวณเจ็ดหัวเมือง ข้อ 30 แสดงให้เห็นว่า ทางราชการไม่ได้พึงเล็งถึงคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งตะไต้ะยุติธรรมเป็นข้อสำคัญแต่ประการใด เพียงแต่เป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามและรู้กฎหมายอิสลามก็เพียงพอแล้ว

ต่อมาเมื่อมีสารตราที่ 30/4353 ของกระทรวงยุติธรรมได้กำหนดตำแหน่งตุลาการฝ่ายอิสลามให้เรียกว่าตะไต้ะยุติธรรม มีหน้าที่เป็นผู้ปรับบทกฎหมายเป็นตุลาการบังคับคดีแพ่งประเพณีอิสลามเทียบอำนาจศาลแขวงในพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาตรา 25 อำนาจของตะไต้ะยุติธรรมคือเป็นผู้พิจารณาคดีแพ่งว่าด้วยครอบครัวมรดกโดยตะไต้ะยุติธรรมต้องทำคำพิพากษาโดยลงชื่อ 2 นาย หรือ ลงชื่อพร้อมด้วยผู้พิพากษาศาลจังหวัดรวมเป็น 2 นาย

ส่วนวิธีคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งตะไต้ะยุติธรรมตามสารตราที่ 30/4353 ของกระทรวงยุติธรรมได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งตะไต้ะยุติธรรมเอาไว้ชัดเจนกว่า กฎฉบับสำหรับปกครองบริเวณเจ็ดหัวเมือง โดยได้กำหนดคุณสมบัติเอาไว้ดังนี้ คือ

1. เป็นบุคคลที่ชาวอิสลามในจังหวัดนั้นเคารพนับถือ
2. เป็นผู้ก่อปรด้วยวิญญูติควรแก่เคารพนับถือในฐานะผู้ใหญ่
3. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในหลักกฎหมายอิสลามพอสมควร
4. เป็นผู้มีความใจจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและภักดีต่อราชการ

แผ่นดิน

สำหรับการเลือกสรรบุคคลที่สมควรจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตะไต้ะยุติธรรมนั้น เป็นหน้าที่ของเทศบาลจะปรึกษาหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อมีความเห็นว่า ผู้ใดสมควรจะได้รับการแต่งตั้งเป็นตะไต้ะยุติธรรมแล้วให้รายงานมายังกระทรวงยุติธรรมเพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต¹

¹ กัรร พันธ์ลาภ, "ตะไต้ะยุติธรรม", การสัมมนาการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลาและสตูล, กระทรวงยุติธรรม 2525, หน้า 325 (คัดจาก ดูหาห เล่ม 10 ปีที่ 5 ตุลาคม 2501)

อย่างไรก็ตามสำหรับวิธีการเลือกตั้งตะโต๊ะยุติธรรมตามลารตราที่ 30 /4353 ของกระทรวงยุติธรรมนั้น ในทางปฏิบัติที่ปรากฏหลักฐานทางราชการในปี พ.ศ. 2471 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้เชิญโต๊ะอิหม่าม มาออกเสียงและผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดก็จะได้รับแต่งตั้งเป็นตะโต๊ะยุติธรรม เหตุที่โต๊ะอิหม่ามเกี่ยวข้องในการเลือกตั้งตะโต๊ะยุติธรรมนั้น ตามหลักคำสอนอิสลามสำหรับประเทศที่มีเจ้าผู้ครองนครเป็นอิสลามคำลินิก เจ้าผู้ครองนครจะเป็นผู้แต่งตั้งตำแหน่งตุลาการนี้เอง แต่สำหรับประเทศที่ไม่มีเจ้าผู้ครองนครเป็นอิสลามคำลินิกก็อนุโลมให้โต๊ะอิหม่ามเป็นผู้เลือกตั้ง เพราะถือว่าโต๊ะอิหม่ามเป็นผู้นำของชาวมุสลิมและเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางศาสนา ผู้ที่จะเป็นโต๊ะอิหม่ามได้ต้องได้รับการคัดเลือกจากอิสลามคำลินิกแห่งมัลลิดนั้น ๆ โต๊ะอิหม่ามจึงเท่ากับเป็นตัวแทนของชาวมุสลิมทั้งหมด¹ ดังนั้น วิธีการเลือกตะโต๊ะยุติธรรมโดยให้โต๊ะอิหม่ามเป็นผู้คัดเลือกจึงได้รับการกระทำสืบต่อมา

ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการตุลาการ พ.ศ. 2471 ซึ่งเป็นกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการตุลาการฉบับแรกนั้นไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติกล่าวถึงตะโต๊ะยุติธรรมไว้ในพระราชบัญญัตินี้เพราะคำว่า ข้าราชการตุลาการในพระราชบัญญัตินี้จะหมายถึงผู้พิพากษาหากินความถึงตะโต๊ะยุติธรรมไม่ ดังจะเห็นได้จากความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัตินี้บัญญัติว่าผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นข้าราชการตุลาการนั้นจะต้องได้ฝึกหัดเป็นผู้พิพากษาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และเป็นที่พอใจของเลขาธิการกระทรวงยุติธรรม ฉะนั้นจึงเข้าใจว่าวิธีการบรรจุและแต่งตั้งตะโต๊ะยุติธรรมในสมัยที่ได้ประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้แล้วคงดำเนินไปตามระเบียบเดิม²

6) การร่างหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวมรดก เนื่องจากกฎหมายอิสลาม ว่าด้วยครอบครัวและมรดกซึ่งจะต้องนำมาใช้แทนบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นมีลักษณะเป็นลัทธิทางศาสนา การยกขึ้นใช้บังคับคดีจะต้องเอามาจากคัมภีร์กิตาบในคำสอนอิสลามซึ่งเป็นภาษามาลายู และภาษาอาหรับ ตะโต๊ะยุติธรรมอาจอ้างคัมภีร์กิตาบแสดงความเห็นขัดแย้งได้ ไม่สะดวกแก่การวินิจฉัยชี้ขาดคดีกระทรวงยุติธรรมจึงได้ตั้งกรรมการประกอบด้วยตะโต๊ะยุติธรรมและผู้พิพากษาบางท่านตรวจชำระคัมภีร์กิตาบลัทธิคำสอนอิสลามอัน

¹ พัทธน์ จักรางกูร, กฎหมายอิสลาม, อ่างแล้ว, หน้า 315.

² เรื่องเดียวกัน, หน้า 326.

เกี่ยวกับครอบครัวและมรดก แล้วจัดทำคำแปลเป็นภาษาชื่อว่า "หลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก" และได้พิมพ์แจกจ่ายให้แก่คำศัพท์ต้องใช้ทุกศาลและให้ถือฉบับนั้นเป็นหลัก เมื่อเสร็จการประชุมแล้วจึงได้ทำบันทึกขึ้นฉบับหนึ่ง ให้ตะโตะยุติธรรมและผู้ร่วมการประชุมลงนามไว้ว่า เมื่อมีคดีเกิดขึ้นตะโตะยุติธรรมจะชี้ขาดบังคับคดีตามหลักกฎหมายอิสลามที่รวบรวมไว้นี้ตลอดไป หากมีปัญหาใดซึ่งไม่มีกล่าวไว้ในหลักกฎหมายนี้จะบังคับได้ก็ให้นำบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดแย้งกับหลักกฎหมายนี้ และเมื่อตะโตะยุติธรรมเข้ารับหน้าที่ใหม่ก็ได้ถือ เป็นระเบียบว่า จะต้องให้ผู้ที่จะได้รับแต่งตั้งใหม่รับรองคำแปลหลักกฎหมายอิสลามดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานว่า จะใช้คำแปลหลักกฎหมายอิสลามนั้น เป็นหลักวินิจฉัยข้อพิพาทในคดีอัน เกี่ยวด้วยครอบครัวและมรดกจะไม่นำคำพิพากษาอ่านอื่นใดมาใช้บังคับแก้คดีดังกล่าวแล้ว เป็นอันขาด หลักกฎหมายอิสลามดังกล่าวได้ตรวจชำระคำแปลและจัดพิมพ์เสร็จเมื่อ พ.ศ. 2484 แต่เนื่องจากในปี พ.ศ. 2486 ได้มีประกาศพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติให้ใช้พระราชบัญญัติ บรรพ 5 และ บรรพ 6 ซึ่งเป็นผลให้ยกเลิกใช้กฎหมายอิสลามอันเกี่ยวกับครอบครัวและมรดก ใน 4 จังหวัดภาคใต้ ฉะนั้น ความจำเป็นที่จะต้องมีการแก้ไขกฎหมายอิสลามจึงเป็นอันระงับมาจนกระทั่งถึง พ.ศ. 2489 ได้มีประกาศพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลาและสตูล พ.ศ. 2489 แล้วจึงได้มีคำสั่งกระทรวงยุติธรรมให้ถือคำแปลหลักกฎหมายอิสลามนั้นเป็นหลักบังคับคดีอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกต่อมาจนบัดนี้¹

3. สถานการณ์ของกฎหมายอิสลามในปัจจุบัน

สถานการณ์ของกฎหมายอิสลามในปัจจุบันโดยพิจารณาจากแนวนโยบายของรัฐในการใช้กฎหมายอิสลามใน 4 จังหวัดภาคใต้ ตั้งแต่สมัยเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี พ.ศ. 2475 จนถึงปัจจุบัน โดยพิจารณาจากแนวนโยบายการใช้กฎหมายอิสลาม ดังนี้

ก) การประกาศใช้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 และ บรรพ 6 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้เมียในประเทศไทยในสมัยก่อน ๆ อยู่ในรูปแบบประเพณีดังจะเห็นได้จากพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยผิดผู้เมีย พ.ศ. 1904 และพระราชบัญญัติเพิ่มเติมว่าด้วยการแบ่ง

¹ กักร พันธ์ลาภ, ตะโตะยุติธรรม, อ้างแล้ว, หน้า 329.

บันลีนบรคณหระหว่างผัวเมีย 1905 ในสมัยพระเจ้าอู่ทองแห่งกรุงศรีอยุธยาซึ่งต่อมารัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้รวบรวมกฎหมายต่าง ๆ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาขึ้นเป็นลักษณะผัวเมีย รวมอยู่ด้วยในกฎหมายตราสามดวง ครั้นต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล มีความจำเป็นที่จะต้องประมวลกฎหมายใหม่ให้มีความสมบูรณ์เยี่ยงอารยประเทศ ประกอบกับ เพื่อให้ได้เอกสารทางศาลเนื่องจากมีคนต่างด้าวเข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงสยามเป็นจำนวนมาก รัฐบาล ของประเทศต่าง ๆ ไม่มีความไว้วางใจในกฎหมายและการใช้กฎหมายในทางศาลจึงได้แทรกแซง การพิจารณาคดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการชำระสะสางเกี่ยวกับกฎหมายครอบครัว และได้ตราเป็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2478¹ นอกจากนั้นแล้วกฎหมายลักษณะมรดก ของประเทศไทยก็มีลักษณะของจารีตประเพณีแต่โบราณเช่นเดียวกับกฎหมายลักษณะผัวเมีย จึง ได้รับการปรับปรุงแก้ไขโดยตราเป็นบรรพ 6 แห่งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2478

แม้รัฐบาลจะได้ประกาศใช้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 และ บรรพ 6 แต่รัฐก็มี นโยบายแน่วแน่ที่จะให้ประชาชนใน 4 จังหวัดภาคใต้ได้ปฏิบัติศาสนิกกิจให้เป็นไปตามลัทธิศาสนา อิสลามซึ่งได้ยกเว้นไม่ให้เอาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 5 และบรรพ 6 มา บังคับใช้ใน 4 จังหวัดภาคใต้ ตามพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติ บรรพ 5 มาตรา 6² และพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติ บรรพ 6 มาตรา 4³ ทำให้การใช้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ไม่กระทบกระเทือนกฎหมายข้อบังคับสำหรับปกครองบริเวณ 7 หัวเมือง ร.ศ. 120 ในส่วน

¹ ชาติชาย อัครวิบูลย์ และสมบูรณ์ ชัยเดชสุริยะ, คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ บรรพ 5 (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์นิติบรรณาการ, 2522,) หน้า 1.

² มาตรา 6 บทบัญญัติแห่งบรรพนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงกฎข้อบังคับสำหรับปกครอง บริเวณ 7 หัวเมือง ร.ศ. 120 ในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยครอบครัว

³ มาตรา 4 บทบัญญัติแห่งบรรพนี้ไม่กระทบกระเทือนถึงกฎข้อบังคับสำหรับปกครอง บริเวณ 7 หัวเมืองในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วยมรดก

ที่เกี่ยวกับครอบครัวและมรดก ซึ่งหมายความว่า แม้จะได้ประกาศใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 5 และบรรพ 6 ก็ตาม การพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวและมรดกที่คู่ความนับถือศาสนาก็ต้องเป็นไปตามกฎข้อบังคับสำหรับปกครองบริเวณ 7 หัวเมืองเช่นเดิม

เป็นที่น่าสังเกตว่าแม้จังหวัดสุลตจะไม่ได้รวมอยู่ในบริเวณ 7 หัวเมืองดังกล่าวและการใช้กฎหมายอิสลามต่าง ๆ ก็เป็นไปตามลัทธิตราที่ 30/4353 ของกระทรวงยุติธรรมซึ่งพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 5 และบรรพ 6 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ทั้ง 2 ฉบับ ไม่ได้กล่าวถึงก็ตามก็ไม่กระทบกระเทือนถึงการใช้กฎหมายอิสลาม ในจังหวัดสุลตซึ่งเรื่องคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาประมวลกฎหมายที่ออกใหม่ ได้ชี้แจงว่า นับแต่วันที่มีลัทธิตรา ขาวอิสลามในจังหวัดสุลตก็ตกอยู่ในบังคับแห่งกฎข้อบังคับสำหรับปกครองบริเวณ 7 หัวเมือง ร.ศ. 120 ทั้งนี้เพราะปรากฏข้อความในลัทธิตราว่า เป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะใช้กฎหมายอิสลามบังคับแก่ราษฎรที่นับถือศาสนาอิสลามทั่วพระราชอาณาเขตคาบสมุทรมาลายูพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 5 และบรรพ 6 ไม่มีข้อความปรากฏให้ยกเลิกลัทธิตรากฎข้อบังคับสำหรับปกครองบริเวณ 7 หัวเมืองนั้นมุ่งถึงกฎหมายที่ใช้อยู่ และมีข้อความดังนั้นอันบังคับตลอดถึงจังหวัดสุลตด้วยมิได้หมายถึงอาณาเขต 7 หัวเมืองตามภูมิศาสตร์¹

ข) พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 5 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พุทธศักราช 2477 พุทธศักราช 2486 และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติ บรรพ 6 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พุทธศักราช 2477 พุทธศักราช 2486 การใช้กฎหมายอิสลามใน 4 จังหวัดภาคใต้มาจนถึงปี พ.ศ. 2486 ซึ่งอยู่ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ในระหว่างนั้นรัฐได้ใช้นโยบายรัฐนิยมและชาตินิยม จึงได้ออกพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติ บรรพ 5 และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติ บรรพ 6 โดยรัฐบาลเห็นว่าสมควรจะได้ขยายบทบัญญัติบรรพ 5 และบรรพ 6 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้ทั่วถึงเพื่อความมั่นคงและวัฒนธรรมของชาติ² โดยมาตรา 3 ของพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติม

¹ พินิจ สักการกิจ, กฎหมายอิสลาม, อ้างแล้ว, หน้า 309.

² คำปรารภของพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติ บรรพ 6 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พุทธศักราช 2477 พุทธศักราช 2486.



พระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติ บรรพ 5 ได้ยกเลิกมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติ บรรพ 5 และมาตรา 3 ของพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติ บรรพ 6 ได้ยกเลิกมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติ บรรพ 6

ผลจากการยกเลิกมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติ บรรพ 5 และยกเลิก มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติให้ใช้บทบัญญัติบรรพ 6 ซึ่งได้กำหนดให้บทบัญญัติแห่งบรรพ 5 และ บรรพ 6 ไม่กระทบกระเทือนถึงกฎข้อบังคับบริเวณ 7 หัวเมือง ร.ศ. 120 ล้นหลั่งลง ทำให้ บทบัญญัติแห่งบรรพ 5 และบรรพ 6 ใช้บังคับครอบคลุมไปถึง 4 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งก็หมายความว่า ตั้งแต่บัดนั้นประชาชนชาวมุสลิมทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่า ด้วยครอบครัวและมรดกเช่นเดียวกับประชาชนส่วนหนึ่งของประเทศ

ค) พระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา สัตตล พ.ศ. 2489 เมื่อสิ้นสงครามโลกครั้งที่ 2 อังกฤษในฐานะผู้ชนะสงครามเริ่มเข้ามา มีบทบาทต่อปัญหาความขัดแย้ง ในภูมิภาคจังหวัดชายแดนภาคใต้ยิ่งขึ้นและสถานการณ์ทางด้าน การเมืองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็อยู่ในภาวะหัวเลี้ยวหัวต่อประกอบกับ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้หมดอำนาจลงพร้อมกับแนวความคิดรัฐธรรมนูญและชาตินิยมรัฐบาลในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงได้ดำเนินนโยบายเพื่อจะกอบกู้สถานการณ์ที่เลวร้ายนั้นให้ดีขึ้น จึงได้ออกพระราชกฤษฎีกา ว่าการด้วยคำสัญญาสัมพันธไมตรีอิสลาม พ.ศ. 2488 และต่อมาจึงได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วย การใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลาและสัตตล พระราชบัญญัติ ดังกล่าว จึงเป็นกฎหมายเพียงฉบับเดียวของไทยที่ได้กำหนดบทบัญญัติ เกี่ยวกับการใช้กฎหมายอิสลาม

เนื่องจากพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวเพียงแต่กำหนดให้ในการวินิจฉัยชี้ขาดคดีแพ่ง เกี่ยว ด้วยเรื่องครอบครัวและมรดกอิสลามคำสันนิษฐานของศาลชั้นต้นในจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสัตตล ซึ่งอิสลามคำสันนิษฐานเป็นทั้ง โจทก์จำเลยหรือเป็นผู้เสนอคำขอในคดีไม่มีข้อพิพาทให้ใช้ กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกบังคับแทนบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ พินิจฉัยว่าด้วยการนั้น โดยมีมติเป็นยุติธรรม เป็นผู้ชี้ขาดข้อกฎหมายอิสลาม

จะเห็นว่า บทบัญญัติของพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลาม นั้น ยังขาด รายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญสำหรับการใช้กฎหมายอิสลามอยู่เป็นอย่างมากจึงทำให้การใช้ กฎหมายอิสลามเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ของรัฐก็ไม่สามารถจะรับรองสิทธิอันเกิดจาก สถานทางครอบครัวตามกฎหมายอิสลามได้

ง) การสัมมนาการใช้กฎหมายอิสลาม

กระทรวงยุติธรรมได้จัดให้มีการสัมมนาการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลาและลือตูล ระหว่างวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2525 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีเหตุผลว่า นับตั้งแต่มีพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลาและลือตูล ตั้งแต่ พ.ศ. 2489 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 35 ปี แล้วยังไม่เคยมีหน่วยราชการใดหรือสถาบันใดจัดให้มีการประชุม หรือสัมมนาเกี่ยวกับการใช้กฎหมายฉบับดังกล่าวนี้เลย ซึ่งเป็นเหตุให้มีปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นเนื่อง ๆ

ในการที่จะแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยและสถาบันต่าง ๆ ของศาสนาอิสลามมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาข้อยุติในปัญหาต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามโดยทั่วกัน

วัตถุประสงค์ในการสัมมนา เพื่อ

1. ให้ศาลและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทราบถึงเจตนารมณ์ของกฎหมาย
2. พิจารณาว่ากฎหมายนี้จะมีผลใช้บังคับนอกศาลเพียงใดหรือไม่
3. ให้มีโอกาสดูแลเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาดัง ๆ ที่เกิดขึ้น

ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

สำหรับหัวข้อในการสัมมนานั้นประกอบด้วย

1. ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายอิสลามใน 4 จังหวัดภาคใต้ เช่น ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ เจ้าหน้าที่ที่ดินสรรพากร และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ
2. ปัญหาการใช้กฎหมายอิสลามใน 4 จังหวัดภาคใต้
3. บทบาท ฐานะและคุณสมบัติของตะโต๊ะยุติธรรม¹

¹โครงการสัมมนาการใช้กฎหมายอิสลาม ฯ การสัมมนาการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลาและลือตูล, กระทรวงยุติธรรม, 2525, หน้า 11-12.

ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอนี้จากการสัมมนา
การใช้กฎหมายอิสลาม¹ โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่พิจารณาข้อเสนอนี้
จากการสัมมนาการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี, นราธิวาส ยะลา และสตูล และเสนอ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายรวมทั้งระเบียบข้อบังคับตลอดจนข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานในส่วนราชการ
ต่าง ๆ

¹ คณะกรรมการประกอบด้วย

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม	เป็นประธานกรรมการ
2. รองปลัดกระทรวงยุติธรรม (ฝ่ายวิชาการ)	เป็นกรรมการ
3. เลขาธิการส่งเสริมงานตุลาการ	- " -
4. อธิบดีผู้พิพากษภาค 9	- " -
5. นายแท่น โต๊ะมีนา	- " -
6. คุณหญิงสมร ภูมิณรงค์	- " -
7. นายวิศิษฐ์ ลิ้มานนท์	- " -
8. นายณรงค์ ศิริปะชะนะ	- " -
9. ผู้แทนกรมการปกครอง	- " -
10. ผู้แทนกรมสรรพากร	- " -
11. ผู้แทนกรมที่ดิน	- " -
12. ผู้แทนกรมตำรวจ	- " -
13. ผู้แทนกรมอัยการ	- " -
14. ผู้แทนจุฬาราชมนตรี	- " -
15. ผู้แทนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน	- " -
16. นายวิชา มหาคุณ	เป็นกรรมการและเลขานุการ
17. นายเจริญ ภักดีธนากุล	เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ที่เกี่ยวกับการใช้กฎหมายอิสลาม ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นคงในชาติ สืบไป¹

ผลจากการสัมมนาครั้งนี้สรุปได้ว่า ยังไม่อาจหาหนทางแก้ไขปัญหาการใช้กฎหมายอิสลามได้ เพราะที่ประชุมสัมมนาส่วนใหญ่มีความเห็นว่าการใช้กฎหมายอิสลามในปัจจุบันมีความเหมาะสมและเป็นธรรมดีอยู่แล้ว หรือถ้าจะมีปัญหาก็สามารถแก้ไขได้โดยทางบริหาร ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่า เหตุผลที่ต้องสัมมนานั้นก็ได้ยอมรับอยู่แล้วว่า การใช้กฎหมายอิสลามนั้นมีปัญหาในทางปฏิบัติของหน่วยงานทางราชการเป็นอย่างมาก จึงได้จัดสัมมนาขึ้นเพื่อให้ศาลและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทราบถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายและปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายในเขตท้องที่ 4 จังหวัดภาคใต้ ตลอดจนหาข้อ เสนอแนะในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น แต่เมื่อมีการสัมมนาเสร็จแล้วกลับมองไม่เห็นปัญหาที่เกิดจากการใช้กฎหมายอิสลาม ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะปัญหาการใช้กฎหมายอิสลามนั้นเป็นปัญหาที่แฝงเร้น เพราะมุสลิม เมื่อเห็นว่าการใช้กฎหมายอิสลามนั้นไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายอิสลามที่ตนศรัทธา เชื่อถือแล้วก็จะวางเฉยต่อสิ่งนั้น โดยจะเห็นได้จากคดีครอบครัวมรดกของมุสลิมที่ฟ้องร้องกันในศาลจึงมีสถิติประมาณ ปีละ 1-2 คดีเท่านั้น ข้อพิพาทส่วนใหญ่จะได้รับความไกล่เกลี่ยและยุติก่อนจะฟ้องร้องในศาล จึงทำให้ปัญหาที่เกิดจากการใช้กฎหมายอิสลามไม่ปรากฏสู่สายตาของหน่วยงานทางราชการมากนัก ส่วนผลสรุปจากการสัมมนา ฯ ในกรณีนี้ที่เห็นว่ามีปัญหา แต่กำหนดวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยทางบริหาร การแก้ไขในทางบริหารนั้นเป็นการแก้ไขปัญหาก็ไม่มีความแน่นอน ไม่มีบรรทัดฐาน ดังนั้น การแก้ไขปัญหาการใช้กฎหมายอิสลามโดยทางบริหารนั้นจึงเป็นการเสี่ยงว่า จะเป็นการแก้ไขปัญหาก็ไม่แน่ชัด หรือสร้างปัญหาเนื่องจากไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายกำหนดเอาไว้

กล่าวโดยสรุปการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศไทยยังมีปัญหายู่มากเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้กฎหมายอิสลามในประเทศอื่น ๆ ปัญหาบางข้อเป็นเรื่องของทัศนคติการยอมรับและความเข้าใจของประชาชนตลอดจนแม้กฎหมายเอง เช่น ทัศนคติที่เข้าใจกันผิดว่ากฎหมาย

¹ หนังสือกระทรวงยุติธรรม ที่ ยธ 0401/5242 เรื่อง คณะกรรมการพิจารณาข้อ เสนอแนะจากการสัมมนาการใช้กฎหมายอิสลาม ลงวันที่ 26 เมษายน 2525

ที่มา การสัมมนาการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูล กระทรวงยุติธรรม, 2525, หน้า 140-141.

อิสลามเป็นกฎหมายต่างชาติดหรือการนำเอากฎหมายอิสลามมาใช้ เป็นการใช้กฎหมายต่าง -
ประเทศ ซึ่งที่จริงแล้วควรเข้าใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมายไทย นอกจากนั้นก็ยังมีปัญหาใน
ตัวกฎหมายและวิธีปฏิบัติอีกหลายเรื่องซึ่งควรแก้ไข ทั้งนี้ได้มีแบบอย่างในต่างประเทศดังกล่าว
ข้างต้นอยู่แล้ว และจะได้ยกมาอธิบายพร้อมทั้งเสนอทางแก้ไขในบทต่อ ๆ ไป



ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย